

身心障礙行不行^{*}

——以訴訟途徑請求公部門落實無障礙設施設置義務的 可行性評析

孫迺翊^{**}

摘 要

我國憲法增修條文第10條第7項及身心障礙者權益保障法均明文國家應建構無障礙環境，體現身心障礙者平等參與社會的人權理念，但這些規定並未真正獲得落實。國內已有身心障礙者依法提起行政訴訟，請求政府落實無障礙環境，惟行政法院認為，依據保護規範說及公物利用關係等學理，身心障礙者並無此等公法上請求權，駁回原告之訴。究竟身心障礙者依據身心障礙者權益保障法之規定，是否享有公法權利？針對此一問題，本文除檢討我國學說與實務見解外，亦將介紹德國聯邦身心障礙者權益平等法之立法例及其司法判決，提出法律解釋與立法政策上的比較分析；本文另將介紹歐洲人權法院幾則判決，說明一般性人權公約對無障礙環境問題未能提供充分之立論依據。最後，本文亦將分析身心障礙者權利公約施行法第8條賦予身心障礙者訴訟權能之意義與功能。

* 投稿日：2014年5月1日；接受刊登日：2014年12月3日。〔責任校對：向民潔〕。

本文為科技部專題研究計畫「身心障礙者平等參與社會之權利及公部門提供無障礙環境之積極作為義務」（科技部計畫編號：NSC 102-2420-H-004-012-MY3）之部分研究成果。作者誠摯感謝匿名審查委員給予寶貴意見，使本文論證過程能夠更加縝密，同時感謝博士生林沛君、碩士研究生黃念儂、陳婉妤、陳乃翊等同學於研究過程中之協助。

** 國立政治大學法學院教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/80406151.pdf>。



關鍵詞：身心障礙者、無障礙、公法上請求權、保護規範說、公物利用關係、聯合國身心障礙者權利公約、公益訴訟、德國聯邦身心障礙者權益平等法。

目 次

- | | |
|----------------|----------------|
| 壹、問題背景之說明 | 二、以公益訴訟方式促使國家 |
| 貳、身心障礙者權益保障法無障 | 履行無障礙環境設置義務 |
| 礙環境之行政訴訟案例 | 之可行性 |
| 一、請求排除障礙環境訴訟 | 三、以個人主觀權利為出發點 |
| 二、請求命公車業者提供無障 | 的無障礙環境訴訟 |
| 礙交通工具訴訟 | 四、德國聯邦身心障礙者權益 |
| 三、小結 | 平等法實踐經驗之檢討 |
| 參、國內有關「公法上權利」之 | 五、德國法制對於我國法制借 |
| 學說與實務見解 | 鏡之意義 |
| 一、保護規範說 | 伍、國際人權公約與憲法增修條 |
| 二、公物利用之權利或反射利 | 文第10條第7項無障礙環境條 |
| 益 | 款之內涵補充 |
| 三、小結 | 一、一般性人權公約與身心障 |
| 肆、以訴訟方式促使國家履行無 | 礙者人權 |
| 障礙環境設置義務之可行 | 二、身心障礙者權利公約內國 |
| 性——以德國法制為例 | 法化對於我國無障礙環境 |
| 一、德國身心障礙權益立法發 | 訴訟之意義 |
| 展與無障礙環境政策 | 陸、結語 |

壹、問題背景之說明

我國憲法增修條文第10條第7項明文國家應建構無障礙環境，並應扶助身心障礙者自立與發展。身心障礙者權益保障法（以下稱「身權法」）就無障礙環境作了非常詳細的規範，包括政府應辦理無障礙環境之服務（第52條）；訂定無障礙設計規範（第52條之1）；建置無障礙網站（第52條之2）；邀集運輸營運者提供無障礙運輸（第53條）；道路、騎樓應符合無障礙相關法規（第54條），並應訂定無障礙號誌、標線等相關規範（第55條）；新建及既有之公共建築物與活動場所之無障礙設施應符合相關設置規範（第57條）。從立法例而言，我國具備了從抽象憲法到具體法律與法規命令完整的規範體系，體現了身心障礙者平等參與社會的人權理念，相較於憲法第155條「老弱殘廢者，國家應給予適當之扶助與救濟」，憲法增修條文及身權法之規範內涵，較能貼近2006年聯合國身心障礙者權利公約（UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD）所揭櫫的「人權模式」或「社會模式」。

所謂人權模式或社會模式，與過去主流的「醫療模式」觀點不同之處，在於如何界定障礙、相關政策又如何回應障礙者的需求。在醫療模式觀點下，所謂障礙係指身障者個人身體上或精神上缺陷因素，導致個人的不幸與不足，身心障礙政策著重於個案的醫療、復健、照護與支持，司法院釋字第417號解釋有關身障者無法使用天橋、地下道，直接穿越馬路是否應受道路交通管理處罰條例處罰之討論，乃是此種觀點的最佳例證。該號解釋認為道路交通管理處罰條例規定，行人逕自穿越設有地下道、天橋之馬路必須受罰，尚不違反比例原則，惟考慮殘障人士或其他行動不便者等難以使用之因素，「參酌同條例第七十八條第二款對有正當理由不能穿越天橋、地下道之行人不予處罰之意旨，檢討修正上開規則」。換言之，身障者若無法上下階梯使用天橋、地下道者，應屬有正當理由

之情形，不應予以處罰；劉鐵錚大法官對此提出不同意見，劉大法官認為如此反足以陷行動不便人士於危險虎口之中。無論是解釋文或劉大法官之不同意見，均僅著眼於個別身障者能否免罰，而未體認到身心障礙者寸步難行、甚至必須違法而行的障礙，乃是整體法規、公共設施未考量身障者需求的結構性問題，以致陷入罰之過苛，不罰卻又等同於將身障者推至險境之論證盲點。相對地，在社會模式觀點下，身障者無法安全過馬路的障礙，並非只是其個人身體功能缺陷所致，更關鍵的因素是來自社會總體對身心障礙者的結構性排斥或忽略，公共設施從未考量身障者的困難與需求，身障者行不得也，這才是障礙所在；而基於人人生而自由平等的人權價值理念，國家應提供無障礙設施，確保身心障礙者與一般國民一樣享有同等的機會，行使憲法上保障的基本權利¹。

1 人權模式／社會模式應是2007年身心障礙者權益保障法全文修正時才導入，在此之前身權法有關身心障礙之界定，仍侷限在醫療模式觀點。有關身心障礙政策從醫療模式到社會模式的轉變，以及身障者人權論述之發展脈絡，有諸多西文文獻可參考，see Theresia Degener, *Disability as a Subject of International Human Rights Law and Comparative Discrimination Law*, in *THE HUMAN RIGHTS OF PERSON WITH INTELLECTUAL DISABILITIES* 151, 151-84 (Stanley S. Herr, Lawrence O. Gostin & Harold Hongju Koh eds., 2003); see Gerard Quinn & Theresia Degener, *HUMAN RIGHTS AND DISABILITY: THE CURRENT USE AND FUTURE POTENTIAL OF UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF DISABILITY* (2002); Jerome E. Bickenbach, *Disability Human Rights, Law, and Policy*, in *HANDBOOK OF DISABLED STUDIES* 565, 565-84 (Gary L. Albrecht, Katherine D. Seelman & Michael Bury eds., 2001)。中文文獻則有黃源協，身心障礙福利的發展趨勢與內涵——國際觀點的分析，社區發展季刊，104期，頁342-359（2003年）；王國羽，聯合國身心障礙者人權公約對我國的啟示，社區發展季刊，123期，頁106-116（2008年）；王國羽、呂朝賢，世界衛生組織身心障礙人口定義概念之演進：兼論我國身心障礙人口定義系統問題與未來修正方向，社會政策與社會工作學刊，8卷2期，頁193-235（2004年）。法學論文參見廖福特，從「醫療」、「福利」到「權利」——身心障礙者權利保障之新發展，中研院法學期刊，2期，頁167-210（2008年）；孫迺翊，再探視障按摩保留條款之合憲性——大法官釋字第649號解釋的法事實與法釋義，中研院法學期刊，9期，頁97-109（2011年）。

那麼基於社會模式／人權模式的觀點，應如何理解「無障礙」(barrier-free, Barrierefreiheit)的概念？身權法雖有諸多條文使用無障礙一詞，然並未就此給予法律上之定義。不過，從身權法第五章「支持服務」明文之各項政府作為義務，包括公共場所建築物、人行道、交通號誌、交通工具、政府資訊提供、語音手語等溝通服務等各種不同面向，應可歸納其核心內涵，亦即各種身心障礙者無須他人協助，透過無障礙設施能夠獨立自主地從事一般人也能從事的任何活動。國際人權法上，2006年聯合國身心障礙者權利公約第9條所稱之無障礙措施，係指為使身心障礙者有能力獨立生活和充分參與生活所應採取之各種適當措施，以確保身心障礙者與一般人係立於平等的基礎上，無障礙地進出物質環境、使用交通工具、利用資訊與通訊，以及使用各種開放公眾使用之設備和服務。

在臺灣雖有上述身權法相當進步的立法，然而實際狀況卻是，街道馬路上的導盲磚經常將視障者導引至障礙物，或導入人車雜沓的危險環境，或為違規停放的汽機車所阻擋；臺鐵小型車站林鳳營站因缺乏無障礙設施，必須仰賴人力協助身障者上下車，身障者請求台鐵站務人員協助時，卻遭到該站副站長以「殘障的又來了」等歧視性言語對待²；國立大學直接於招生資訊上註明：「有視覺障礙或辨色異常、聽覺障礙、肢體障礙者，宜慎重考慮」，表明該校缺乏無障礙設備，無法支持身障者就讀該系所，或者儘管設有美輪美奐的無障礙宿舍寢室，宿舍出入口卻無坡道可供輪椅通行，以致從未有行動不便的身障生入住該宿舍³；甚至有身障人士晚間返家

2 張雅如，身障者與台鐵的平權抗爭，身心障礙e能網，2011年6月30日，<http://www.enable.org.tw/magz/detail.php?id=433>（最後瀏覽日：2015年4月6日）。

3 例如國立政治大學歷史學系之大學部入學資訊，<http://www.history.nccu.edu.tw/admission/recruit.php?Sn=1>（最後瀏覽日：2015年4月6日）。林維德、吳玉帆，政大無障礙宿舍無坡道，肢障生不願住，公民新聞，2013年12月26日，<http://www.peopo.org/news/228205>（最後瀏覽日：2015年4月6日）。

時，因一般計程車後車廂無法裝載電動輪椅，臨時又叫不到復康巴士，只能獨自操作電動輪椅，勉強從臺北市忠孝東路端的慢車道直上忠孝橋往三重行進，因橋上最外側無斜坡設計，輪椅無法爬上人行道與自行車道，只好行進於慢車道，不幸因天雨視線不清被車輛從後方追撞受重傷昏迷不醒⁴。

這些舉隅並非少數個案，實際生活中身心障礙者的行動與自主決定處處遭遇障礙，大多由身心障礙者權益倡議團體透過召開記者會、陳情抗議的方式，督促政府部門重視與改進，但政府部門常以預算有限、目前已逐步落實或將作為來年施政重點為由加以回應，相關設備設施尚未改善之前，身障者仍須容忍種種不便，接受個人自主決定與行動自由受限的現實⁵。在此，法律人必須面對一個根本性的問題：究竟上述法律的規範效力與規範意義為何？當身障者自主行動受限时，有無可能尋求司法救濟途徑排除障礙，或透過司法判決促使政府立即履行其法律上義務？從身權法第53條、第54條、第57條等規範體例觀察，其規範對象為中央主管機關或各級政府，要求其應制定或遵循相關無障礙規範，提供無障礙服務、設備或設施，身障者能否據此主張無障礙設備或設施設置請求權，頗有難度。

即便勝算不高，國內已有身心障礙者踏出第一步，針對公園、運動場的管理單位及公立學校於出入口放置路障，阻礙身心障礙者進入的行為提起給付訴訟，接著又有行動不便者針對縣政府未督促公車業者行駛低底盤公車，幾經協調未果，提出行政救濟。一如預期，兩案之判決結果原告之主張均告敗訴。在兩項訴訟行動挫敗之後，任職於法扶基金會的視障律師李秉宏有意推動修法，明文規定

4 陳明里，大道之行也，人輪平等——從下肢行動不便者的行路權、大眾交通運輸服務談起，法律扶助會訊，33期，頁22-23（2011年）。

5 李明政等，弱勢者教我們的事：社會工作之權利導向，頁161-166（2013年）。

身權法所定各項公部門無障礙設施設置義務，均為身障者可得主張之公法上請求權。此外，李律師也與身心障礙者團體共同呼籲立法院應該比照2009年訂定聯合國公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法模式，將聯合國身心障礙者權利公約內國法化，因為兩公約無法涵蓋身心障礙者特殊的人權問題，而國內身權法是以「提供福利」的角度來立法，唯有將身心障礙者權利公約內國法化才能轉換視野，從「人權」而非僅「福利」的角度來檢視身心障礙者權益問題，包括無障礙設施之個案救濟⁶。

究竟現行身權法有關政府應設置無障礙環境之相關規定，是否足以作為身障者透過訴訟途徑督促政府履行其義務的法律依據？我國憲法增修條文第10條第7項國家應設置無障礙環境之規定，對於身權法規定之解釋與適用，具有何種規範作用？行政法院於上述兩項訴訟案件所持見解應值得分析探究，在此主要涉及保護規範說及公物利用關係等爭點。基於上述第一項問題意識，本文以下先整理分析我國行政法院判決（第貳部分）以及國內學說實務見解，歸納法理上尚待突破之處（第參部分），接著介紹德國聯邦身心障礙者權益平等法（*Behindertengleichstellungsgesetz, BGG*）之立法例及其判決實務，說明如何以訴訟方式促使國家履行無障礙環境設置義務，再回到我國的規範脈絡，分析如何將憲法增修條文「無障礙環境」的規範觀點運用於保護規範說，適用於無障礙環境訴訟，以突破國內兩項行政法院判決之論述盲點，並提出強化公益團體程序參與地位、設置公益訴訟之立法政策建議（第肆部分）。針對第二項問題意識，本文將介紹目前歐洲人權法院幾項相關判決，指出一般人權公約確有如李秉宏律師所指無法涵蓋身心障礙者人權議題的盲點，對於充實我國憲法增修條文第10條第7項「無障礙環境」的規

6 李秉宏，有關我國為何需加入「聯合國身心障礙者權利公約」的緣由，身心障礙e能網，2013年11月22日，<http://www.enable.org.tw/iss/detail.php?id=252>（最後瀏覽日：2013年12月29日）。

範內涵幫助有限，就此身心障礙者權利公約毋寧提供較為具體的論述依據（第伍部分），以期能為國內身心障礙者人權提供法學釋義及立法政策上的論述基礎（第陸部分）。

在進入以下分析討論之前，先說明本文何以選取德國法及歐洲人權法院判決作為比較研究的素材。本文借鏡德國立法例，主要是因為我國行政法及行政訴訟法大量繼受自德國，德國法上如何運用保護規範說、如何解決訴訟權能問題以及行政法院如何審查行政機關有無履行提供無障礙環境之義務，對於我國法律之解釋適用具有參考價值。而本文介紹歐洲人權法院判決，主要是因為公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約在我國雖已內國法化，但兩公約並未如歐洲人權公約設有人權法院提供較為完備的個案救濟程序⁷，歐洲人權法院就國家是否履行設置無障礙環境之義務已有數則判決可供參考，較能具體呈現一般性人權公約就身障者人權的保障有何不足。至於與本文直接相關的身心障礙者權利公約歷史較短，累積之申訴案件與一般性意見不多，故於「伍、二、身心障礙者權利公約內國法化對於我國無障礙環境訴訟之意義」再作補充說明。另須附帶說明者，從實現身心障礙者的平等參與社會權利觀點而言，法律亦應明文規範私有建築物、營業場所之所有人負有設置無障礙設施之義務，惟本文探討對象為公部門之公法上義務，不及於私人之設置義務。

⁷ 公民與政治權利國際公約本身僅設有國家報告義務而無個人申訴制度，只有簽訂其第一任擇議定書之國家的國民，才有機會向公約第28條所設置之人權事務委員會（Human Rights Committee）提出個人申訴（individual communications）。經濟社會文化權利國際公約直到2008年之前，亦僅有經濟社會文化委員會審查國家報告的監督機制，並無任擇議定書提供個人申訴制度。

貳、身心障礙者權益保障法無障礙環境之行政訴訟案例

面對身權法上諸多政府設置無障礙設施規定落實程度有限的困境，已有身心障礙者開始尋求訴訟途徑尋求救濟。經查詢司法院裁判系統目前已有兩例：高雄高等行政法院98年度訴字第186號判決應是身障者首次採取訴訟方式，希望藉由司法裁判督促主管機關落實無障礙環境之提供，該項訴訟判決原告敗訴，經上訴至最高行政法院，以最高行政法院100年度判字第1454號判決上訴駁回而告確定（該案例以下稱「請求排除障礙環境訴訟」）。該次訴訟失敗之後，又另有身障者家屬提起行政訴訟尋求救濟，經臺北高等行政法院101年度訴字第527號判決及最高行政法院101年度裁字第1931號裁定駁回，同樣敗訴（該案例以下稱「請求命公車業者提供無障礙交通工具訴訟」）。

一、請求排除障礙環境訴訟

（一）案例事實暨原告與被告機關之主張

原告甲為使用輪椅之身心障礙者，在提起行政訴訟之前，其父親曾就高雄縣多項公共設施包括高雄縣立體育場，以及鳳西、文華、文山等三所高雄縣鳳山市內公立國小等，其於出入口設置路障，周邊道路路口有高低落差，以及人行道上有鐵椅、四角石磚等物，阻礙使用輪椅之身心障礙者出入等情形，請求各管理單位改善。為此，內政部及高雄縣政府曾多次召開協調會，會中作成若干改善決議，各管理單位亦進行改善，惟甲父認為改善結果仍未達法規標準，乃由甲向高雄高等行政法院提起給付訴訟，請求各管理單位移除障礙，並設置無障礙設施⁸（詳如下表1）。原告主張，其係

⁸ 本案提起訴訟之原告為甲及甲父，但甲父有當事人適格問題，關於此點本文暫不予討論。

依照「高雄縣身心障礙者權益受損協調處理辦法」第4條提出申訴、再申訴，對於申訴結果不服提起行政訴訟，應能提起行政訴訟以為救濟。而其請求各管理單位作為之依據，包括國民體育法第7條規定「校園在不影響學校教學及生活管理的情形下，應配合開放，提供社區民眾體育活動之用」；另外身權法第54條、第57條有關市區道路、人行道、騎樓及公共建築物、活動場所之無障礙設施，授權主管機關訂定規範，內政部早已於建築技術規則建築設計施工編訂有相當詳盡之施工規範。

被告機關高雄縣政府及各公立國小就校園出入口設置鐵條鐵鍊等路障提出答辯，其主張因為校園管理人力不足，為避免機車於校園開放時間內進入校園，對校園內活動之學童、居民造成危險而設置，並無意圖阻礙身心障礙者進入使用校園，再者甲對於公共設施之利用，僅有反射利益而已，欠缺公法上請求權基礎，無從要求被告機關為一定之作為。另就無障礙設施部分，高雄縣政府及鳳山巒市公所均以當年已編列年度預算辦理無障礙設施，惟經費有限，僅能逐一改善辦理；至於休閒椅係供民眾休憩使用，四角石磚係為維護行人安全，不宜移除。

表1 欠缺無障礙設施之公共設施情形暨原告起訴之主張

管理單位	原設置缺失	協調會後之改善狀況	未予改善之處原告起訴主張
高雄縣立體育場	- 鐵條橫阻大門及側門之出入口。 - 周邊道路路口有高低落差。 - 人行道上設置休閒椅，阻礙出入。 - 未能妥善安排人車分道管理動	- 大門設置24小時警衛，開放時間內，保持大門打開至一定空間，足使行動不便者出入；大門增設服務鈴，並移除側門入口鐵條。 - 高低落差處設置	- 移除體育館小門、側門及周邊之鐵條、鐵椅、四角石磚。 - 改善周邊人行道路之路緣斜坡。

	線。	斜坡道，惟僅便於輪椅通行，未能兼顧所有弱勢族群使用。 • 人行道上休閒椅未拆除。	
高雄縣鳳山市鳳西國小	- 學校出入口設置鐵鍊鐵條，阻礙身心障礙者出入。 - 周邊道路路口有高低落差。	- 增設斜坡道，惟其寬度與高度皆不足，電動輪椅仍無法進入校園。 - 移除學校出入口之鐵條。	- 移除鳳西國小正門、側門口之入口扶手。 - 改善學校周邊通學步道路緣斜坡。
高雄縣鳳山市文華國小	- 學校出入口設置鐵鍊鐵條，阻礙身心障礙者出入。 - 校外人行道有障礙不利通行。	學校出入口雖設有可供輪椅進出之出入口，惟採半開方式，未達無障礙環境通路最小90公分之規定。電動輪椅仍無法進入校園。	- 移除文華國小正門、西門、北門之入口扶手。 - 改善學校周邊通學步道路緣斜坡。
高雄縣鳳山市文山國小	學校出入口設置鐵鍊鐵條，阻礙身心障礙者出入。	- 僅將一處小門鐵鍊撤除，惟該出入通道坡度過陡。 - 為防止機車進入校園，學校側門出入口仍設置鐵條。 - 縮減開放時間，改為週一至週五下午4點至6點，週休二日不開放。	- 移除文山國小東門、西門設置之鐵鍊。 - 依照無障礙環境設計規範設計出入口。

高雄縣政府	• 安寧街上台電變電箱阻礙身障者通行。 • 社會處廣場（即婦幼館青少年館）之車止、石磚阻礙身障者出入。	• 移除安寧街上台電變電箱。 • 於安寧街設置臨時斜坡道。	• 請求移除社會處廣場上之障礙物。
高雄縣鳳山市公所	• 人行道上之鐵椅及四角石磚阻礙身障者通行。 • 移除或改善臨時斜坡之設置。 • 未按建築物無障礙設施，設計市區道路工程。	• 鐵椅供休憩使用，四角石磚為維護安全，其設置於步道上較為寬廣位置，不妨礙身障者使用輪椅通行。 • 經費有限，僅能逐一改善，惟已雇工改善三個無障礙坡道。	• 請求移除鐵椅及四角石磚。 • 請求移除或改善臨時斜坡。 • 請求依照內政部建築物無障礙設施設計道路工程規劃。

資料來源：本文作者。

（二）高雄高等行政法院98年度訴字第186號判決之見解

關於原告是否具有公法上請求權的主要爭點，高雄高等行政法院分別從「公物使用」及保護規範說兩個不同觀點切入。就公物利用關係而言，法院認為依照通說，人民對公物之一般利用性質，僅屬反射利益，或有認為應視利用人對該公物之利用程度而定，惟縱認原告依其依賴關係，對公物有使用之權利，亦僅限於已設置之公物，而不及於「請求設置公物」，人民對此尚無公法上權利。另就保護規範說而言，身權法第57條有關新建公共建築物及活動場所應設置無障礙設施及設備，以及第88條之罰則規定，係為維護身障者

之合法權益及生活，保障其公平參與社會生活之機會，無障礙設備或設施若有不足，應由各級目的事業主管機關責令所有權人或管理機關負責改善，並給予處罰，這些條文並未賦予身障者得向公共建築物或活動場所之所有人或管理機關請求設置個別公有營造物，縱有提出，僅係促其注意予以改善而已，原告並不具有公法上請求權利。

退步言之，縱認原告得提起本件訴訟，法院亦認為相關機關已經進行改善，至於三間國小所為之校門管理措施，係為維護校內利用設施民眾安全，尚屬適當，與身障者之權益無違，同樣地，步道上之鐵椅及石磚係供民眾休憩或為維護民眾安全所設，其設置在步道上較為寬廣之位置，並不妨礙身障者使用輪椅之通行，因此原告之主張亦無理由。

（三）最高行政法院100年度判字第1454號判決之見解

最高行政法院駁回上訴，不過其理由與高等行政法院不盡相同。最高行政法院同樣認為，身權法第54條、第57條均非賦予身障者本件公法上請求權基礎之法條，且上訴人之請求項目涉及諸多工程之施作，涉及機關預算支用，須事前現地勘驗規劃，始能核算所需人力物力經費。法院認為，上訴人原審訴之聲明係請求被上訴人移除或改善不利行動不便者通行之設施與設備，其請求內容之性質為行政事實行為，屬於公法上一般給付訴訟，就此，上訴人不僅須有公法上請求權，且須該訴訟可直接行使給付請求權，如依實體法之規定，須先由行政機關確定或核定其給付請求權者，則應提起課予義務訴訟，請求作成核定之行政處分，不能逕行提起給付訴訟。本件改善工程涉及被上訴機關之預算與財政能力，應尊重行政機關之審查權限，請求權人應先向主管機關為申請，遭拒絕時，先提起課予義務訴訟，請求作成核定處分。行政法院並未具有上級機關之功能，不得取代行政機關自行決定，若允許上訴人提起一般給付訴

訟，「實造成行政法院先行剝奪行政主管機關依法規劃及預算之權限，容有不宜」。

二、請求命公車業者提供無障礙交通工具訴訟

在臺北高等行政法院101年度訴字第527號判決中，原告家住桃園，其母為身障者，平日以桃園客運、中壢客運及新竹客運之公車代步，三家客運公司多以遊覽車改裝為公車營運，上下車階梯非常高，對身障者極不方便，乃向交通部公路總局及桃園縣政府陳情，請求兩行政機關應限制轄下公車業者轉用遊覽車為公車作為營運工具。交通部公路總局函覆原告，說明其近兩年積極輔導業者購置低底盤公車，也組成「通用化交通環境推動小組」，邀請區監理所、業者及相關身心障礙者權益團體（以下簡稱身障者權益團體），擇訂相關具體可行路線，行駛低底盤公車，研訂可行之完成期限，逐步改善。桃園縣政府亦函覆原告，其已補助業者購置八輛低底盤公車，先運行某些路段，後續年度將持續積極推動；另提供復康巴士供領有身障手冊之民眾預約訂車，提供運輸服務。

原告不服兩行政單位之函覆提起訴願，訴願機關以上述兩件函覆非行政處分不予受理，接著提起行政訴訟，請求撤銷上述兩件系爭函文，命交通部公路總局及桃園縣政府應各作成對轄下公車業者轉用遊覽車為一般公車為限制之行政處分⁹，其主張之法律依據為身權法第16條、第53條、第99條、第102條，及大眾運輸工具無障礙設施設置辦法第4條至第7條（相關條文請參考本論文之附錄）。

臺北高等行政法院同樣援引保護規範說及司法院釋字第469號解釋，針對原告是否具有公法上請求權表示其意見。法院認為上開規定並非為保障特定人而設，難謂被告機關對人民負有特定作為義務而不作為之情形，因此原告請求被告機關為一定作為之請求缺乏

9 原告另請求損害賠償，因與本論文所探討之主題無直接關連，暫予省略。

公法上請求權之依據。人民既無公法上請求權，其向被告機關所為之請求，僅屬行政程序法第168條所定之陳情，被告機關即無依陳情內容為準駁或作為之法定義務，據此，系爭兩項函文非屬行政處分之性質，不得對之提起撤銷訴訟。原告不服本項判決，再為上訴，經最高行政法院101年度裁字第1931號裁定以上訴不合法，裁定駁回。

三、小結

上述兩項案例主要涉及身權法第53條第1項「各級交通主管機關應依實際需求，邀集相關身心障礙者團體代表、當地運輸營運者及該管社政主管機關共同研商，於運輸營運者所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車（機船）廂（艙），提供無障礙運輸服務」、第54條「市區道路、人行道及市區道路兩旁建築物之騎樓，應符合中央目的事業主管機關所規定之無障礙相關法規」及第57條第3項前段「公共建築物及活動場所之無障礙設備及設施不符合前項規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善」等規定，法律雖然明定行政機關提供無障礙環境與無障礙交通工具之作為義務，但是否也賦予身心障礙者相對的公法上請求權，得據以向法院提起訴訟，命行政機關為一定之作為，應是關鍵問題所在。行政法院援引保護規範說（Schutznormlehre）之學理，以系爭條文之規範對象均為行政機關為由，認為系爭法律規定並未賦予身心障礙者此等公法上請求權；另從公物利用的角度，法院亦認為人民對公物的一般性利用僅受有反射利益而無公法上請求權。行政法上保護規範說及公物利用等抽象學理，究竟如何運用在具體個案中，身權法相關規定又如何從學理加以解讀，法院判決論理並不充分，容有進一步探究之必要。

參、國內有關「公法上權利」之學說與實務見解

一、保護規範說

（一）學說與實務見解

一般而言，有關公法權利與反射利益之區分，於法律明文規定授與權利時，可依據該規定認定權利存在；法律僅就義務為規定而未明文授與權利時，除為達成公共利益之外，如目的亦同時在於確保個別人民之利益，人民即因而具有公權利，反之，該義務規定之目的若僅在達成公共利益，個別人民因而間接獲得利益者，則僅屬反射利益，人民不得因反射利益受到侵害而提起行政爭訟¹⁰。究竟如何解釋法規之目的是否同時追求公益與保護個人利益，國內通說援引德國學說見解，以保護規範說為判斷標準，此項學說廣為國內學者所接受¹¹，並為司法院釋字第469號解釋所採，該號解釋理由書第一段謂：「法律規範保障目的之探求，應就具體個案而定，如法律明確規定特定人得享有權利，或對符合法定條件而可得特定之人，授予向行政主體或國家機關為一定作為之請求權者，其規範目的在於保障個人權益，固無疑義；如法律雖係為公共利益或一般國民福祉而設之規定，但就法律之整體結構、適用對象、所欲產生之規範效果及社會發展因素等綜合判斷，可得知亦有保障特定人之意旨時，則個人主張其權益因公務員怠於執行職務而受損害者，即應許其依法請求救濟」（粗體為作者所加），亦即探求法律規範目的，來判斷行政機關不作為導致人民權益受有損害時，人民能否請求國家賠償。

¹⁰ 法治斌，行政法律關係與特別權力關係，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁224（2006年）；陳敏，行政法總論，7版，頁254-255（2011年）；陳新民，行政法學總論，8版，頁123-127（2005年）。

¹¹ 法治斌（註10），頁225；陳敏（註10），頁256-257；林騰鶴，行政訴訟法，4版，頁105-106（2011年）；陳清秀，行政訴訟法，6版，頁257-263（2013年）。

如何探求法律規範目的，涉及法律的解釋。就此，德國公法學界又以二次大戰之時點為界，有新、舊保護規範說之分，其主要差異在於，依照舊說，公法上權利之規範基礎首先係從憲法基本權利規定加以探求，新說則力主公法權利之探求應遵循法律優先原則，應先從法律著手，而非憲法基本權利規定；且解釋法律時，舊說以立法者之主觀意旨作為探求規範意旨之切入點，新說則不限於立法者的主觀意旨，尚從法規之規範體系及整體制度之框架條件加以考量¹²。學者進一步分析，新舊學說須分別從其法制上之歷史脈絡加以理解：舊說時代下，憲法上基本權利規範並未直接賦予人民防禦國家公權力侵害的主觀權利效力，人民是否享有公法上權利，完全取決於立法者的意志，因此當時發展保護規範說，其主要功能在於建構人民遭遇行政權違法干預時享有排除侵害的公法上權利，尤其是藉由撤銷訴訟以除去違法行政處分之訴訟請求權；相對地，戰後在基本法憲政國家秩序下，人民如果遭受公權力侵害，本於憲法基本權利之防禦功能，人民即得提起撤銷訴訟以資救濟，基本上已無應用保護規範說之需要；而基本權除防禦權功能外，更具有價值決定的客觀功能，但它需要先由立法者就社會資源作公平分配、授予行政機關相關權限與任務，適當界定私人間的權利義務關係，在此範圍內人民是否享有公法上權利，無法直接援引憲法基本權規定，而須取決於立法決定，以法律為依據，特別是關於國家設備的積極創設或一定金錢或物質的積極給付，因涉及國家財政能力、國家資源之運用及社會利益調整等因素，除非屬於人民生存的最低限度保障，否則應由立法者決定，此時透過新保護規範說的詮釋，法院得以判斷這些法律規定是否賦予人民公法上權利，得以提起第三人訴訟、課予義務訴訟或給付訴訟¹³。德國法運用新保護規範說，在建

12 詳見李建良，保護規範理論之思維與應用，收於：黃丞儀編，2010行政管制與行政爭訟，頁257-259（2011年）。

13 李建良（註12），頁259-268。法治斌教授亦提醒，以法律規範說詮釋法規時，

築法與環境法兩大領域擴張了第三人訴訟、鄰人訴訟的訴訟權能¹⁴，我國實務見解受到新說影響，於此兩大領域亦有進展¹⁵，至於如何用以解釋適用身權法，尚未見國內文獻就此有所討論，亟待進一步分析探究。

在障礙環境中，身心障礙者無法如一般常人行使其自由權，例如道路高低不平，肢障者即無法如同常人般享有一般行動自由權、集會遊行自由、職業選擇自由、受教育權；同樣地，生活環境中缺

應考量憲法中有關人權之規定；其中個人自由權之部分尤得引以為據，至於新近興起之受益權，其中有關經濟、社會之給付請求權，因係要求國家必須積極有所作為，涉及國家財力負擔及有限資源之配置與利用，須有法律進一步規定始有運作之可能，除非係屬人民生存權之最低生活保障，或基於平等權所生之參與請求權，此類公法權利之存在可能性甚為有限。參見法治斌（註10），頁226。

14 Wolfgang Kahl著，林明鏘譯，德國與歐盟行政法上主觀公法上權利之現況、演變及其展望，臺大法學論叢，40卷2期，頁886-891（2011年）；劉如慧，歐洲法對德國行政法的影響——以個人權利保護之訴訟權能為例，成大法學，17期，頁7-16（2009年）。晚近德國保護規範說受到來自歐盟法的挑戰。在歐盟法，有關歐盟運作條約第263條非特權原告無效訴訟之訴訟權能，其中「與已直接且個別相關」之要件，歐盟法院判決認為僅利益遭到侵害即為已足，且會員國所為具有一般效力的法律行為直接涉及自身而無須再藉助實施措施者，亦得對之提起無效訴訟，不要求到達德國法上「權利」遭受侵害的程度；同條約第267條先決裁判訴訟的訴訟權能亦較德國法寬鬆，只要歐盟法規具有保護人民利益之目的，則可能的事實利害關係人即具有訴訟權能。論者認為，透過較為寬鬆的訴訟權能認定，可使人民擔任行政的守護者角色，使其得以向該國法院提起訴訟，藉由會員國法院對該國行政之監督，再透過歐洲法院對歐盟法之解釋，達到有效維護貫徹歐盟法、促成歐盟整合之目標。究竟歐盟法對德國保護規範說產生何種影響，環境法領域是否應放棄保護規範說主觀權利受損之嚴格標準，德國文獻討論相當豐富，國內亦有相關之介紹與引述。由於歐盟法上之討論與本文無直接關連性，本文暫不作討論，相關中文文獻可參考Wolfgang Kahl著，林明鏘譯（註14），頁891-905；劉如慧（註14），頁22-35；陳柏霖，論行政訴訟中「公法上權利」——從德國法與歐盟法影響下觀察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁80-105（2011年）。

15 就此亦有諸多文獻，例如盛子龍，撤銷訴訟之訴訟權能，中原財經法學，7期，頁1-46（2001年）；總覽性介紹則可參見李建良，行政訴訟實務十年掠影（二〇〇〇年至二〇一〇年），月旦法學雜誌，182期，頁19-62（2010年）；劉如慧，我國環境影響評估法判決回顧，興大法學，7期，頁275-308（2010年）；莊國榮，行政法，頁96-97（2013年），相關實務見解之整理。

乏點字、語音等設備，視障者的受教育權、職業選擇自由、一般行動自由即大幅受限；投票所缺乏無障礙設施，視障者與肢障者即無法行使其政治參與權。在外觀上，公權力並未透過法律、行政處分或行政事實行為「限制」身心障礙者的職業選擇自由、集會遊行自由、一般行動自由、政治參與權利，因此無法僅從基本權利之防禦權功能取得公法上權利的基礎¹⁶。換言之，此種類型的權利行使限制，並非來自公權力之積極干預，而是公權力忽視身心障礙者的存在、未將社會資源配置於無障礙環境所致，身心障礙者能否在無障礙環境中享有與一般人同樣的基本權利，毋寧需要國家調整資源配置重點、調節社會利益衝突；而立法者既已於身權法中明確要求國家積極規劃創設交通工具、公用設施、公用建築物的無障礙環境，以落實憲法增修條文第10條第7項之憲法委託，那麼應有運用新保護規範說檢視相關規定是否賦予身心障礙者「公法上權利」之討論空間。

（二）身權法相關規範之分析

1. 請求排除障礙環境訴訟

「請求排除障礙環境訴訟」涉及身權法第54條規定人行道、市區道路、騎樓應符合無障礙法規；公共場所或活動空間如未符合無障礙規範，同法第57條規定，主管機關應命其所有人或管理單位予以改善。依照新保護規範說，必須檢視該法規是否具有保護身心障礙者個人利益之目的而屬於「保護規範」，最後須判斷原告是否屬

¹⁶ 李建良教授在上開論文中特別指出，基於基本權之防禦功能，除撤銷訴訟上行政處分之相對人應具有訴訟權能外，與行政處分相對人利害與共之第三人，或人民因行政事實行為受到侵害，請求行政機關排除不利結果，其公法上權利及訴訟權能均可自基本權利之防禦功能直接導出。同樣地，基於法律禁止再透過許可制度允許人民為一定之營業行為或財產利用行為者，人民提起課予義務之訴請求行政機關發給許可者，亦得從基本權利之防禦權功能直接推導其公法上權利與訴訟權能之基礎，無須借助於保護規範說。參見李建良（註12），頁265-266。

於該法規所欲保護之對象。高雄高等行政法院98年度訴字第186號判決及最高行政法院100年度判字第1454號判決認為，身權法第54條、第57條並未賦予身障者得向公共建築物或活動場所之所有人或管理機關請求設置個別公有營造物之權利，至多僅促其注意予以改善而已，此項見解容有重新斟酌之餘地。

按身權法第1條明文以保障身心障礙者平等參與社會機會為立法目的，而參與社會活動的前提要件之一，必須身心障礙者能夠如同常人般自由行動，而後才有接受教育、選擇工作、參與戶外活動的可能。立法者於身權法第54條及第57條特別明文，道路、人行道、騎樓均須符合法規所定之無障礙環境，公共建築物及活動場所之無障礙設備及設施不符合前項規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善，其規範目的很明顯地就是為行動不便的身心障礙者所設，確保其能真正享有一般行動自由，甚至能夠自主行動。從保護規範說的學理判斷，身權法上開規定應具有保障身障者行的自由之意旨，其保障對象應可得特定為身心障礙者¹⁷。或者，我們也可以試著反問，這些規定如果不是針對身障者

17 李建良教授於「保護規範理論之思維與應用」一文中，認為應可分三層次加以分析保護規範說如何應用於一般給付訴訟：一、原告之請求是否有法規上之依據？二、解釋該法規是否屬於「保護規範」，三、判斷原告是否屬於上開規定之保護對象？本件案例事實與身權法第54條、第57條之規範模式與李教授文中所舉高速公路周邊居民請求高工局依噪音管制法規定設置隔音牆之案例類似（臺北高等行政法院92年度訴字第1594號判決），李教授對該案之論述分析應可作為身權法規範解釋之對照參考。

該案涉及舊噪音管制法第10條規定，道路交通噪音「由主管機關會同該主管機關採取適當措施防制之」，同法施行細則第10條並規定，道路交通噪音經住戶請求改善，並經主管機關檢測超過標準者，應通知各該目的事業主管機關採取適當防制措施。依學者李建良之分析，這些規定不無保護住戶免於噪音侵擾之目的，不失為保護規範，但能否作為建構公法上權利之基礎，尚須從憲法保障人民基本權利之意旨及噪音管制法之規範目的綜合研判。噪音管制法第1條規定，「維護國民健康」為其主要立法宗旨，在此所謂「國民健康」，乃涉及人民受憲法保障之健康權，且非僅針對抽象、不特定之公眾，參酌同法有關噪音標準以及上述道路交通噪音改善措施之規定，這些規定應係針對直接蒙受噪音侵擾之道路沿線附近居民，應屬一種保護規範，只要居住於道路沿線者，即為系

的社會參與機會平等與人格自主發展而設，那麼該項立法究竟欲追求何種公益？該項公益又將歸諸於誰？唯有當我們尊重身心障礙者作為基本權主體，體會障礙環境對其自主發展的阻礙，才能解釋何以在我國憲法基本權清單之外，憲法增修條文第10條第7項另要求國家應建構無障礙環境，然後再透過身權法具體決定政府應將資源配置於哪些具體項目，也才不致將個別、具體的身心障礙者化約成抽象的一般公共利益。

儘管立法目的相當明確，法院仍採取否定見解，推測其主要考量係政府預算配置及司法是否具備判斷無障礙環境的專業能力。最高行政法院於100年度判字第1454號判決中即指出，無障礙設施之改善工程涉及機關之預算與財政能力，應尊重行政機關之審查權限，因此要求身心障礙者必須先向主管機關為申請，遭拒絕時，再提起課予義務訴訟，請求作成核定處分。最高行政法院藉此將是否拆除障礙或施作無障礙設施之決定權轉回行政機關，先由主管機關為「核定是否施作」之行政處分，將法院介入的時點延後，迴避法院就此類個案進行實質審查的可能性。

如果再仔細斟酌原告主張與判決理由，可以發現法院似乎並未真正理解原告的主張。本件訴訟中原告並未要求公物之管理單位「設定」公物，而是請求既存且供公眾使用之公物的管理維護單位排除路障、弭平高低差，無論管理單位是否移除，對原告而言應未產生任何法律效果而僅屬事實行為，尚不足以構成行政處分，原告提起的行政救濟應為一般給付訴訟，而非課予義務訴訟¹⁸。況且，即便原告依照最高行政法院之見解，先向主管機關申請改善，再循

爭保護規範效力所及，具備請求設置噪音防制措施之公法權利。參見李建良（註12），頁297-301。

18 按身權法第57條第3項前段規定：「公共建築物及活動場所之無障礙設備及設施不符合前項規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善」，如所有權人或管理機關為私人，則目的事業主管機關依據本項規定及第88條罰則規定，的確有可能對該私人作成命其改善之行政處分。

訴願、提起課予義務之訴等途徑，最終仍難以獲救濟：首先，行政訴訟法第5條規定，人民提起課予義務訴訟，須中央或地方機關對其「依法申請之案件」於法令所定期間內應作為而不作為，行政法院就「依法申請」作相當嚴格之解釋，限於人民依據法律有向行政機關申請對其作成一定行政處分之權利而言，法律未規定有申請權，或法律並非規定人民得申請行政機關對其作成一定行政處分者，均不符合上開要件¹⁹，依此標準，上述身權法第54條、第57條等並無身心障礙者得就此申請行政機關作成行政處分之規定，系爭個案原告若向縣政府及公立小學「申請」改善無障礙環境，恐怕亦無從提起課予義務訴訟以為救濟；其次，即使放寬課予義務訴訟要件之認定，依上述行政法院之見解，仍可能以身權法並未賦予身障者向行政機關請求改善的公法權利而駁回原告請求。因此，最高行政法院認為原告應先依法申請，再行提起課予義務之訴，並非真正可行的救濟途徑。

2. 請求命公車業者提供無障礙交通工具訴訟

「請求命公車業者提供無障礙交通工具訴訟」之原告係依據身權法第53條規定，請求公路客運主管機關限制轄下客運業者不得使用遊覽車作為客運。該事件中，原告先向公路局、桃園縣政府請求改行駛無障礙公車，而後才針對行政機關之函覆提起訴願、行政訴訟。臺北高等行政法院101年度訴字第527號判決同樣以保護規範說檢視身權法第53條規定，認為上開規定並非為保障特定人而設，難謂被告機關對人民負有特定作為義務而不作為之情形。實則，身權法第53條規定主管機關應協調交通運輸業者提供無障礙運輸服務，大眾運輸工具無障礙設施設置辦法第7條明確具體地規定道路及公

¹⁹ 最高行政法院90年度判字第1637號判決、最高行政法院93年度裁字第1537號裁定。學者對於行政訴訟法第5條「依法申請」之規範方式及實務上狹義解釋方式，有批評之意見。參見李建良（註12），頁285-286；陳敏（註10），頁1377-1378。

車應符合之階梯高度及升降設備規格，對於不合格之運輸業者，第99條賦予行政機關命其改善、甚至給予行政處罰之權責，均是以實現身心障礙者受憲法保障之行動自由為規範目的，也是身權法第1條保障身障者平等參與社會機會、促進其自立之具體規定，其所欲保護之個人利益相當具體明確；而原告居住桃園，請求主管機關就其經常利用之三家公車路線營運業者改善運輸服務，其屬該條保護規範之對象所及，應無疑義。

二、公物利用之權利或反射利益

此外，在上述請求排除障礙環境訴訟中，高雄高等行政法院另從公物利用關係切入，認為人民對人行道、步道、公立體育館及開放民眾進入時段的公立國小操場運動設施等公物利用，僅屬反射利益，並無公法上權利可得主張，此項論點涉及公物利用關係究為人民公法上權利或反射利益之區分，學說見解未盡相同，頗有爭論。早期實務與學說均認為僅屬反射利益，以行政法院53年裁字第39號判例所持見解為代表²⁰，不過晚近受到人權保障思想影響，此項見解開始鬆動。學者李惠宗認為應視利用人對該物之依賴程度，判斷其是否有利用之權利：倘若利用人之生活或權利行使必須利用該公物始得展開者，即有「依賴關係」存在，此時具有利用權利；反之利用人對公物如無依賴關係存在而自由使用，其不存在或利用狀態受阻時，利用人仍有其他替代方法，其利用則為「反射利益」²¹。

20 范揚，行政法總論，2版，頁206-207（1955年），氏提及當時通說採反射利益說。行政法院53年裁字第39號判例謂：「查該項修訂都市計畫所關涉之台北市華陰街，係屬公用道路，原告之利用通行，僅屬一種反射利益，並非就該項道路有何種權利存在，縱令修訂都市計畫內關於將華陰街舊路原10公尺寬度修縮為4尺，妨礙車輛通行，確有不合之處，亦難謂該項修訂都市計畫係有損害原告之權利，即與提起行政訴訟之要件不合」。本號判例已經最高行政法院91年10、11、12月份庭長法官聯席會議決議不再援用。

21 李惠宗，公物法，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁361-364（2006年）。學者李震山贊同此一見解，參見李震山，行政法導論，7版，頁126（2007年）。

權利與反射利益之間，呈現相對化的狀態，非可一概而論：李教授認為依賴利用關係之認定，須參考社會一般生活型態及時代需要個別認定，且不限於具有唯一性者，例如亟需公園綠地地區為該公園之利用可認為具有依賴關係，路人路過公園進入休憩，僅受有反射利益；再者，即便我國地方制度法第16條第3款明文地方自治團體居民「對於地方公共設施有使用之權」，其構成要件空疏，且同屬地方自治團體下的居民，就特定公物之利用程度未必同等²²。學者陳敏對於公用道路使用則直接採取權利說，就現有供一般使用之公用道路，陳教授認為人民具有依提供公用及交通法規而為使用之「公權利」，而非僅受有反射利益，不過人民之行動自由，並不包括請求國家修築或維持特定道路之權利在內²³；至於道路以外其他公物之利用，陳教授則未作進一步分析。

上述李惠宗教授所提「依賴利用」與「事實利用」之分，已為部分法院判決所採²⁴，本件高雄高等行政法院同樣援引李惠宗教授的見解，以公物法之觀點切入，檢討原告對於步道等系爭公物是否有利用之權利，惟法院並未給予明確的答案，僅曖昧不明地表示：「縱認人民依其依賴關係有一般使用公物之『權利』，亦無從認人民有請求設置公物之主觀請求權，蓋公物之設置涉及行政主體為遂行行政活動所必要之基礎手段，屬公物法及組織行政法（物的組織）之一環」。實則，身心障礙者無法享有公平機會接近、使用公物的問題關鍵，並不在公法權利或反射利益之區別。上述學說有關人民有無利用公物權利之判斷標準，並不分公物使用人為老人、幼童或

學者吳庚、黃俊杰對此則未明確表示其見解，參見吳庚，行政法之理論與實用，12版，頁186（2012年）；黃俊杰，行政法，3版，頁240-241（2011年）。

22 李惠宗（註21），頁361-364。

23 陳敏（註10），頁1032。

24 例如高雄高等行政法院100年度訴字第181號判決認為居住在臺北的民眾，對於住所所在地高雄住家附近的既成道路，並無依賴利用關係，僅享有反射利益；高雄高等行政法院91年度訴字第1136號判決逕認既成道路利用人只享有反射利益。

身障者，乃抽象地一體視之。身心障礙者對於住家附近公園、學校操場、體育館及其連接道路，可能依其依賴程度分別具有使用的公法權利或僅有反射利益；而無論是公法權利或反射利益，只要公共設施通道或出入口設有路障、地面有高低差，一般人使用上沒有差別，輪椅族實際上即受阻擋而無法使用。要言之，問題的核心在於使用公物的「機會不平等」，即便偶爾至體育館看球賽聽演唱會、每日傍晚至國小操場散步運動僅屬人民利用公物之反射利益，身障者也無法享有與一般人相同之使用利益！也因此，身權法第16條第2項才會特別明文規定：「公共設施場所營運者，不得使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利」，法院竟完全忽略此項規定。本文認為，從公物利用究竟為反射利益或公法權利的角度切入，反而使問題失焦，未能真正切中身障者所面臨的困境，也完全忽略了身權法有關無障礙環境規定的立法意旨。

三、小結

綜上分析，國內兩項判決所著墨的公法權利爭點，無論是保護規範說，或是公物利用關係的詮釋，法院判決先引述學說依據，套用於系爭案例事實與法規時，既未深究身權法之規範目的，法律所定行政機關的作為義務是否足夠具體明確，亦未討論這些作為義務與身心障礙者行動自由之間的關連性，即認定僅屬反射利益，論理十分薄弱貧瘠。事實上，從保護規範說之變遷及大法官解釋意旨可知，個別法律規範是否賦予人民請求公行政為一定作為或不作為之權利，容有詮釋的彈性空間；它可能因有權解釋適用法律之機關，著眼於不同的適用對象，或考量法律規範效果與社會發展因素，隨著時空因素變化而改變見解，將原先認為僅屬反射利益之規定詮釋為賦予人民公法權利之規定。在請求排除障礙環境訴訟中，儘管原告援引憲法增修條文第10條第7項國家應推動無障礙環境之規定，身心障礙者的人性尊嚴未獲平等尊重，又以聯合國身心障礙者權利公約有關「基於身心障礙的歧視」、「合理便利」與「通用設計」等

規範作為論述佐證，這些憲法與國際人權法對能否充實保護規範說之內涵，用以分析身權法相關規定的屬性，法院均未置一詞；甚至在公物利用關係的論述上，僅著眼於抽象的「人民」有無利用公物的權利，而未真正「看到」行動不便、會呼吸、有感官的身心障礙者被阻絕於社會參與的困境，未體認到身障者根本沒有平等的機會享有公物利用的反射利益。由此顯示，相較於環境法或建築法，法院對於身心障礙者權益保障法之立法意旨以及身障者遭遇的行動困境仍然非常陌生。

針對上述從人權理念到憲法規範，從憲法規範到身權法相關規定的推論分析，再到法院應如何實質審查行政機關有無履行法定作為義務等不同層次的問題，國內相關討論非常有限，以下第肆部分先以我國公法主要繼受國德國法為例，介紹德國如何透過立法及法學釋義，解決並落實基本法第3條第2項要求之身心障礙歧視禁止規定。

肆、以訴訟方式促使國家履行無障礙環境設置義務之可行性——以德國法制為例

德國身心障礙法制之發展，在國際比較上並非特別進步，不過從公法釋義學的角度，德國如何從法律制度實踐無障礙環境、訴訟途徑遭遇何種困難，對於我國仍有值得參照借鏡之處。

一、德國身心障礙權益立法發展與無障礙環境政策

（一）傳統身心障礙復健政策（Rehabilitationspolitik）

德國有關身心障礙法制，長期以來係建構在所謂「復健政策」上，1998年之前柯爾政府時期，尤其是80年代期間，身心障礙政策重點在於給予個別身心障礙者復健措施，使其能夠盡量適應、配合

依照常人需求所設置的一般生活環境，主要的法律制度散見於各項社會立法，例如社會法典第3編就業促進法、第5編法定健康保險法、第6編法定年金保險法、第7編職業災害保險法，其他社會補償立法亦有復健給付，例如「聯邦因公受傷軍人照顧法」(Bundesversorgungsgesetz)給予因公受傷致殘軍人相關復健措施。這些相關法律彼此之間並非立基在一完整架構上，事權分散、標準不一，常有同一情形依照不同法律、由不同主管機關提供不同給付的情形，為此還特別制訂「復健給付整合法」(Gesetz über die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation, RehaAngG)，不過不同主管機關彼此間的合作協調並未因該法之訂定而獲得落實。除此之外，身心障礙復健政策還面臨許多的挑戰，例如復健措施通常由機構執行，將身心障礙者隔絕於社會之外，再者復健費用高昂，但未必能真正協助身心障礙者重返社會，即便一位受過良好輪椅操作訓練的肢障者能夠自行跨越人行道與馬路間的高低差，但無論如何不可能期待他以輪椅爬上樓梯。由此即突顯出復健政策僅著眼於身障者個人適應社會能力，卻忽略了生活周遭條件的結構性障礙因素²⁵。

(二) 增訂德國基本法第3條第3項第2句

在憲法層次，德國基本法第3條第1項保障人民不因其身心障礙而受到法律上歧視，同條第2項、第3項再將一般平等原則進一步具體化，第2項禁止男女性別歧視；基於納粹時期慘痛經驗，第3項又將出身、種族、宗教信仰等等明文列為禁止歧視事由，在1994年之前尚未包括「身心障礙」(Behinderung)。有鑑於世界諸多國家憲法均明文保障身心障礙者不受歧視，國家並有促進身心障礙者融入社會的義務，而兩德統一後德東五邦憲法均設有身心障礙者社會權保

²⁵ Stefan Straßmair, Der besondere Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, 2002, S. 54-66.

障條款，再加上歐盟法與國際人權法的影響，促使德國開始思考是否應於憲法明文保障身心障礙者，最後於1994年修憲，增訂基本法第3條第3項第2句，將「身心障礙」列入，確保任何人不因其身心障礙而受到不利待遇（Benachteiligung）²⁶。依照該條款之規定，公權力不得以身心障礙者為分類標準，使身心障礙者受到不利差別待遇，除非具有重大公共利益事由能正當化該不利差別待遇，但不禁止對身心障礙者為優惠性差別待遇。身心障礙者依據基本法之規定，享有防禦權功能的平等權應無疑義。

有疑義者係基本法第3條第3項第2句的規範效力，是否及於身心障礙者所受事實上的不利處境，其非僅止於直接來自於法律上歧視的效果？此種事實上不利處境，經常涉及國家消極不作為。對此學說見解歧異，端視如何解釋基本法第3條第1項規定而定，通說堅持基本法第3條平等原則僅限於禁止法律上歧視，不及於事實上不平等，至於國家是否有義務排除視障者面對的事實上不利處境，通說認為不屬於基本法第3條平等原則的規範範疇，立法者基於社會國原則之憲法委託義務，對於如何促進身心障礙者的社會融入，則享有廣泛裁量空間。相對於此，少數見解認為基本法增訂身心障礙者條款，最主要的目的即在促進身障者與非身障者之間的平等，如果公共建築物出入口均為階梯，以致輪椅代步的身障者無法進入，即屬對身障者的不利對待，此種解釋不僅將「不利對待」的概念擴張至間接歧視與結構性歧視，也將大幅限縮立法者基於重要公共利益對身心障礙者為差別待遇的裁量空間，準此，基本法第3條第3項第2句將不再純屬防禦權功能，而是趨近於賦予身障者向國家請求作為的原始給付請求地位²⁷。

²⁶ *Straßmair* (Fn. 25), S. 126-136.

²⁷ 詳見*Straßmair* (Fn. 25), S. 210-215。持少數見解者以Andreas Jürgens為代表，他曾籌設身障法律人論壇，參與基本法的修憲討論。

聯邦憲法法院對此採取折衷迂迴的立場。依照聯邦憲法法院於「身障學童之融合教育／特殊教育案」所表示之見解²⁸，「不利差別待遇」的概念不僅指公權力制定規範或採取措施致使身障者處於較為不利的情境，例如無法進入公共設施、不能獲得他人可得享有的給付，也包括公權力主體未提供充分的協助措施，致使身障者的人格發展自由受到阻礙或被排除的情形，後者需視具體個案狀況判斷。以本案而言，身障學生想要到一般學校就讀，接受融合教育，教育主管機關予以拒絕而指定其就讀特殊學校，並非當然構成「不利對待」，須具體考慮政府於一般學校配置相關資源的財政能力，以及該指定就讀是否符合教育專業判斷。如果身障生依其能力適合在一般學校就讀，不會造成校方明顯財政負擔，或一般學校已配置特殊教育資源，主管機關卻仍指定其就讀特殊學校，即可能構成不利對待，法院應於個案中綜觀所有條件，衡量身障生與政府財政能力雙方的利弊得失。學者認為，上述聯邦憲法法院見解係參照「衍生性分享權暨給付請求權」（*derivatives Teilhabe- und Leistungsrecht*）之學理，賦予該項條款社會國之內涵²⁹，該項見解認知到身障者相較於常人，其發展自我之自由是否受到不利差別待遇，繫諸於公權力主體究竟提供多充分之協助或補償措施，仍須衡酌資源配置之有限性；而資源配置之決定，依然取決立法與行政部門，聯邦憲法法院就此並未有重大突破。

（三）歐盟法及國際人權公約之影響

相較於基本法，歐盟法、國際人權法及其他國家憲法與反歧視

28 BVerfGE 96, 288 (303)（特殊教育／融合教育案）。此項案例涉及一位五年級身心障礙學童，教育主管機關依鑑定報告，認為該學童需要特殊輔助與輔導，決定將其從一般學校轉至特殊學校受教育。

29 能否由此條款推導出原始之主觀請求權利，目前通說均採取保留態度。Lerke Osterloch, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, 3. Aufl., 2003, § 3 Rn. 305, 312-313; Felix Welti, Rechtliche Voraussetzungen von Barrierefreiheit, NVwZ 2012, S. 725 (725).

立法，對德國身心障礙者權益法制之發展有較為直接明顯的影響。

國際人權法方面，2000年歐盟基本權憲章（Grundrechte-Charta der Europäischen Union）第21條禁止歧視條款包括禁止基於身心障礙之不利差別待遇，第26條宣示歐盟承認並尊重身心障礙者社會融入措施的請求權利，前者相當於德國基本法第3條平等原則，後者則明確承認身心障礙者享有社會基本權，惟該項憲章當時尚屬不具國際法拘束力的宣言³⁰。2009年正式生效的聯合國身心障礙者權利公約以「無障礙」為指導理念，要求締約國應全面落實無障礙環境，使身心障礙者能夠充分參與社會、融入社會。德國聯邦憲法法院曾指出，行政機關與法院必須尊重並遵守德國所簽署的各項人權公約，例如參照歐洲人權公約之意旨解釋適用內國法令³¹，而德國作為身心障礙者權利公約的締約國之一，不僅聯邦政府有履行公約之義務，各邦政府、地方自治團體基於聯邦體制忠誠義務（Bundestreue），亦必須參照公約精神解釋適用各該邦法令及自治規章³²。

歐盟法上，1997年阿姆斯特丹歐洲共同體條約第13條授權共同體理事會於歐體權限範圍內，採取適當措施對抗性別、身心障礙、種族、出身等等歧視，歐體據此制定2000年歐體就業及職業平等指令（Richtlinie des Rats zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, Richtlinie 2000/78/EG），德國必須於內國法上轉換指令意旨，消除就業上的身心障礙歧視。除此之外，在身障權益領域，外國立法例對德國亦有深刻影響，例如2000年愛爾蘭平等地位法（Irish Equal Status Act 2000）、2003年西班牙「身心障礙者平等機會及反歧視

30 2009年生效的里斯本條約第6條明文將歐盟基本權憲章納入歐盟條約內容，歐盟基本權憲章始具有拘束歐盟會員國的法律效力。

31 BVerfGE 111, 307 (315 ff.).

32 *Welti* (Fn. 29), S. 725.

法」(Equal Opportunities and Against the Discrimination of Disabled Persons Act)，以及法學文獻最常討論的1995年英國「身心障礙者歧視法」(Disability Discrimination Act, DDA)³³。各國有關無障礙環境之法律規範，除有與我國身權法內容相近之街道、建築物、公共設施、各種交通工具等無障礙環境之規定外，亦特別關照到保障身心障礙者在權利救濟及立法參與上的機會平等，例如設有身心障礙者權益監察使(Ombudsman)，或是允許公益團體提起訴訟，以強化個別身障者權益受損時之權利救濟³⁴。至2000年為止，德國尚無此種全面性的反歧視立法。

(四) 從復健政策到社會模式／人權理念的轉變

從基本法的身心障礙禁止歧視條款到身心障礙者的實質平等促進，從歐盟平等原則指令的轉換到國際人權法的落實，在在需要內國立法的配合。在人權理念導引下，德國身心障礙者權益法制始有較為明顯的進展，重要的修法與立法工程包括2001年大幅修正社會法典第9編，更名為「身心障礙者復健及社會參與法」(Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, SGB IX)，在身心障礙的定義上強調因身體或精神功能之缺失導致其參與社會受到限制，以身心障礙者的「自主決定權」(Selbstbestimmung)為主要立法意旨，接著分別於2002年訂定「身心障礙者權益平等法」、2006年訂定「一般平等對待法」，或稱「反歧視法」(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG/Antidiskriminierungsgesetz)，前者規範國家積極設置無障礙環境之公法上作為義務，後者則將社會法上「身心障礙」的概

33 Caroline Gooding & Catherine Casserley, *Open for All? Disability Discrimination Laws in Europe Relating to Goods and Services*, in *DISABILITY RIGHTS IN EUROPE: FROM THEORY TO PRACTICE* 135, 135-37 (Anne Lawson & Caroline Gooding eds., 2005).

34 Peter Trenk-Hinterberger, *Teilhaberechte behinderter Menschen in den Mitgliedsstaaten der EU*, in: Maydell/Pitschas/Pörtner/Scuhle (Hrsg.), *Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien*, 2009, S. 277 (299-300).

念納入民法體系，以基本權第三人效力規範私法法律關係上亦不得基於身心障礙因素而給予身障者差別待遇³⁵。

上述三大身障者權益法制中，與本文最為相關者應屬聯邦身心障礙者權益平等法，它僅有15條條文，主要規範重點包括歧視禁止、無障礙環境之設置義務人以及身障者權益落實措施。首先，德國聯邦身心障礙者權益平等法第7條第2項將基本法第3條第3項第2句之身障者歧視禁止之規定作了較為具體規範，其明文聯邦及各邦公權力主體及機關不得給予身心障礙者不利對待，所謂不利對待係指無重大事由而給予身障者與非身障者不同之對待，以致直接或間接減損身障者參與社會之平等機會。其次，同法第4條將「無障礙」定義為身心障礙者在無他人協助情形下，能夠使用各項建築設施或其他設施、交通工具、科技產品、資訊處理系統、視聽資料來源、溝通設備及其他生活領域設備等，不因其身心障礙而遭遇使用上或溝通上的困難。準此，上開條文所欲排除之障礙包括使用接近上及溝通上之障礙（Zugangs- und Kommunikationsbarrieren），點字或盲用電腦即屬溝通上之無障礙設備³⁶。此項無障礙環境之概念，於同法第8條至第11條分別就建築物、交通工具、溝通方式等不同面向作了更為具體之規定，內容相當於我國身權法第五章「支持服務」各項無障礙環境之規定。其中第8條第1項規定聯邦所屬供公眾使用之新建物或既有建物之大幅擴建或整修，均須符合無障礙建築規範，第2項則規定其他建築設施、公共道路、廣場、街道、公共

35 Bernd Petri/Thomas Stähler, Menschenrechte und Behinderung, ZESAR 2008, S. 167 (167-171); Felix Werti, Das Recht auf Teilhabe hinderter Menschen in seinem verfassungs- und europarechtlichen Rahmen und im Spannungsfeld der neueren Sozialgesetzgebung, RsDE 2006, S. 1 (17-18). 有關一般平等對待法於民事法上之適用，參見周伯峰，「歧視禁止」作為私法自治的限制？——簡評德國《一般平等對待法》中的民事法上歧視禁止規定及其爭議，月旦法學雜誌，224期，頁127-150（2014年）。

36 Monika Majerski-Pahlen, in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen (Hrsg.), SGB IX Kommentar, 12. Aufl., 2010, BGG § 4 Rn. 6-7.

交通工具及車站等亦須符合無障礙建築規則³⁷。由上可知，該法所拘束之對象主要為聯邦政府各機關、聯邦政府所設公法人³⁸。至於各邦之落實尚須視各邦規定，除各邦憲法明文保障身心障礙者之機會平等外，柏林邦早在1999年即制定該邦之身心障礙者權益平等法（Landesgleichberechtigungsgesetz vom 17. Mai 1999），明文邦政府負有設置無障礙設施之義務，而Bayern邦及Nordrhein-Westfalen邦則於2003年分別訂定該邦之身心障礙者權益平等法。

德國聯邦身心障礙者權益平等法有幾點值得注意的落實措施，
一、身心障礙者之權利救濟途徑：第12條規定，身心障礙者的權益

37 所謂「大幅」擴建、整建係指其工程費用超過一百萬歐元者，參見Majerski-Pahlen (Fn. 36), § 8 Rn. 4.

38 供公眾使用或提供公眾服務之私人建築物是否亦須配置無障礙設備？聯合國身心障礙者權利公約第9條要求締約國必須採取措施，使身障者亦能接近使用此類私有建築物，或受領私人所提供之服務。惟德國內國法上，能否從一般平等法導出私有建築物之所有人或管理人負有此一義務，仍有疑義，目前營建法及房屋出租法就私人之無障礙環境設置義務設有規定，但未明確規範設置費用由誰負擔，參見Welti (Fn. 29), S. 725。德國聯邦身心障礙者權益平等法第5條則明文，身障者權益團體得與企業或企業聯合會締結目標達成協議（Zielvereinbarung），就企業建築物或工作場所約定無障礙設施之最低標準。關於營建法上之私人財產應設置無障礙設施之規定，曾有身障者之同居人因不堪負荷每天背負身障家人上下三層樓，而向房東請求設置電梯，費用將由該房客自行負擔，未來退租時亦會將電梯拆除，該請求遭房東拒絕，聯邦憲法法院認為私法之法律關係亦應貫徹基本法上身心障礙者不利對待禁止原則，由於相關法令就此尚無規定，房東與房客又無法達成協議，此時法院須依憲法保障身心障礙者免於障礙之意旨，以及民法誠信原則加以判斷；房東使用承租之房屋及樓梯間、通道乃為憲法財產權保障之範圍，如缺少無障礙設施，該承租人即無法使用該房屋，邦法院應依此意旨解釋適用相關之民法條文，作符合憲法意旨之裁判（BVerfGE, NJW 2000, 2658 (2658 ff.))。

再舉一實務上案例說明：熟食肉舖欲擴張營業店面兼營咖啡蛋糕店，向主管機關申請許可，但其供客人使用之廁所與營業場所分離，且不符該邦營建法所定之無障礙設備標準，使用輪椅之身障者無法使用該廁所，主管機關即駁回其申請，店家提起撤銷訴訟，認為受限於該建築物結構無法於營業場所內設置廁所，如果依照規定設置，將大幅減少營業面積而不符成本效益，使其遭受重大不利益，行政法院則為該邦營建法要求私人營業場所擴建整修時必須符合無障礙環境規範，乃為落實基本法第3條第3項第2句之意旨，並未逾越必要界線，而判決店家敗訴（OVG Münster, – 7 A 1977/10）。

受到損害時，得由第13條所定身障者權益團體代理提起法律救濟，或經本人同意參與救濟程序；身心障礙者權益受到損害之情形，包括第6條第2項所指情事，亦即公權力機關如無正當理由，對身心障礙者為不利之差別待遇，或直接、間接使其無法享有社會參與的平等機會³⁹；二、第13條身障者權益團體所提之公益訴訟（Verbandsklage）⁴⁰：經聯邦勞動及社會部（Bundesministerium für Arbeit und Soziales）所指定之公益團體得就政府未落實本法，未落實聯邦層級選舉、歐盟層級選舉及社會保險法人意思機關選舉無障礙規定，未落實餐飲店法、各級公路法、電車興建及營運辦法、鐵路興建及營運辦法、航空法等之無障礙環境規定，以及未落實應提供手語翻譯之相關聯邦法令，提起行政確認訴訟；三、第14條、第15條另設有身心障礙者權益監察人（Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen），其得參與立法或法令訂定過程，以確保身心障礙者融入社會的觀點與需求能夠納入法令訂定的利益衡量範圍，使身障者平等權益能夠突破立法零碎化、彼此欠缺銜接的問題，在法律制度上獲得整體性的解決。就此而言，身心障礙者監察人扮演著身障者權益團體與政府之間的溝通協調角色⁴¹。

在「身心障礙主流化」（Disability Mainstreaming）脈絡下，無障礙設施相關法規雖逐步完善，但這些法令經常因行政部門怠於作為而未能獲得貫徹與落實，使得身心障礙者行動上仍處處受限，無法享有與常人相同之機會行使其自由權利⁴²。德國身障權益人士

39 Majerski-Pahlen (Fn. 36), § 12 Rn. 1-7。社會法典第9編身心障礙者復健及社會參與法第63條亦有相同規定。

40 有關德國身障者權益團體之組織情形，參見Felix Welti, Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechtsstaat, 2005, S. 223-224.

41 Welti (Fn. 29), S. 725. 本篇文章指出，法律另有明文交通運輸路線計畫之擬定必須諮詢身障者權益監察人；甚至營建主計畫（Bauleitplan）擬定過程中，身障者權益團體若參與不足，可能構成裁量瑕疵（Abwägungsmangel）。

42 Welti (Fn. 29), S. 725.

亦批評，身心障礙者的平等權益議題在法學研究上仍未受重視，法學文獻大多侷限於特定法制之給付，而未能從整體法律秩序的觀點來檢視德國身心障礙政策的缺失，有關「社會融入」、「反歧視」等概念在法學上幾乎不具任何重要性⁴³。

二、以公益訴訟方式促使國家履行無障礙環境設置義務之可行性

承前所述，由於德國身心障礙者權益平等法明文經政府認可之身障者權益團體得提起行政訴訟，監督政府是否落實該法之無障礙設置義務，如此訴訟之提起即無須受限於是否有個別之身障者權利因政府之作為或不作為而受損等要件。該項訴訟之提起無須經過先行程序，但僅具備提起確認訴訟（Feststellungsklage）之權能，確認系爭營建計畫是否牴觸無障礙法律規範之規定，而非廣泛地審酌其是否有其他程序或實體瑕疵，因此公益團體不能提起撤銷訴訟、課予義務訴訟與一般給付訴訟⁴⁴。到目前為止，僅出現少數公益訴訟案例，且均未獲得勝訴判決，其理由為何，值得進一步探究。

（一）「歐洲受迫害猶太人紀念碑」（Denkmal für die ermordeten Juden Europas）無障礙設施公益訴訟⁴⁵

「歐洲受迫害猶太人紀念碑」位於柏林著名地標布蘭登堡大門附近，該紀念碑暨紀念館之興建係經德國聯邦眾議院決議訂定相關法律，並以聯邦預算出資設立基金會推動興建，希望能夠時時提醒世人勿忘過去迫害猶太人之歷史，其屬於德國轉型正義法制的一環。系爭紀念碑之設計者Peter Eisenman的設計理念，是想凸顯受

⁴³ Alexander Drewes, Bindertenpolitik in Deutschland aus der Sicht hinterter Menschen, in: Maydell/Pitschas/Pörtner/Scuhlte (Hrsg.), Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien, 2009, S. 151 (156-159).

⁴⁴ Majerski-Pahlen (Fn. 36), § 13 Rn. 1-4.

⁴⁵ VG Berlin, - 19 A 284/02 = NJW 2003, 2927 (2927 ff.).

迫害者面對國家暴力時的茫然無助、孤立無援處境，其表現形式為在基地上興建矩陣形式、高低不一、某些略微傾斜的水泥柱，地面則有起伏，最大落差為2.4公尺，某些柱與柱間僅容一人行走其中，平視或仰望均能感受到無盡的壓迫感。此項設計案中130條柱間通道有13條通道可供電動輪椅通行，其餘大部分柱子傾斜度較高、較為狹窄、有明顯壓迫感的柱間通道，電動輪椅則無法通行其間。此案已由設計者依柏林邦營建法相關規定，向主管機關申請請求部分設施得免除無障礙義務，經柏林邦主管機關以其符合「公共利益」之「必要」等法定要件許可在案。提起訴訟之身障者權益團體主張，此項設計案並未考量使用電動輪椅身障者需求，使用電動輪椅的身障者無法如同常人一般，進入狹窄通道部分感受藝術家所欲傳達的時空壓迫感。

柏林地方行政法院認為，國會為了興建受迫害猶太人紀念碑特別立法並設立基金會推動，以示對歷史的反思並落實轉型正義，符合重大公共利益之要件，在此毋寧是基本法第5條第3項藝術表現自由與身障者的無障礙環境需求二者之間的衝突，法院分別從兩個面向加以討論：若為使電動輪椅能夠完全通行於所有柱間，必須擴大柱間寬度，設計者即無法完整呈現不安、壓迫、孤立的感受，藝術表現自由即因此有所減損；相對地，現行方案中部分柱間阻礙輪椅族之通行是否給予身障者不利之差別待遇，柏林地方行政法院援引德國聯邦憲法法院「融合教育／特殊教育案」有關基本法第3條第3項第2句身障者不利對待禁止條款所表示之見解，認為所謂不利對待不僅指身障者因身體或精神上缺陷使其處於較常人更為不利之處境，例如常人均能進出之建築物，身障者卻因缺乏無障礙坡道而無法進入，更包括國家未提供相關身障協助措施（*Behinderung bezogene Förderungsmaßnahme*）以充分減少阻礙，進而導致身障者發展可能性受到限制或排除之情形，依據此項見解，法院必須依照當時的知識發展階段，就國家是否充分提供協助排除障礙進行實質

評價⁴⁶。不過此項條款並非禁止任何差別待遇，身障者如因欠缺身體或精神上功能之障礙而缺乏行使某項權利之必要條件，此時阻礙其行使該項權利並不牴觸不利對待禁止原則，換言之，如有重大正當事由，仍得對身障者為不利之差別待遇⁴⁷。在本案中，法院認為身障者仍能通行於130條通道中之13條通道，亦可無阻礙地參觀紀念碑下方的紀念館，到達整座建物的最底層，反之如依電動輪椅通行之需求而更改柱間通道寬度設計，將無法完整呈現設計者所欲傳達的意境，因此法院認為主管機關已衡量兩項衝突之利益，其所為之利益衡量並無瑕疵，其給予該設計案部分免除設置無障礙環境義務之許可並未牴觸基本法之規定，而判決原告敗訴。

（二）德國鐵路公司月台無障礙設施公益訴訟

晚近訴訟實務，則出現許多與德國鐵路公司（Deutsche Bahn AG，以下簡稱德鐵公司）車站月台改善營建計畫相關的無障礙環境訴訟。德鐵公司提出一項車站、月台設備現代化的營建改建計畫，改建的目的在於設置電子化塔台、強化Aalen至Ulm這條路線的營運效率，計畫若經審核通過，沿線有些車站會將站體相連接的第一月台（Bahnsteig）及不相連接的第二月台寬度縮減，有些可能會再增設中間一月台，而月台間會設置地下道，各月台並會保留設置電梯的空間，但若個別車站每日旅客流量未足1,000人次的小站，基於財政營運考量，暫時不裝設電梯，日後若旅客流量增加，即可裝設電梯而無須另行施作土木工程。主管機關聯邦鐵路局（Eisenbahn-Bundesamt）分局於計畫審查程序中，已邀請德國聯邦身心障礙者權益平等法所認可的身障者權益團體參加，給予其表示意見機會，最後作成核准處分，惟身障者權益團體認為營建計畫未

46 參照前述特殊教育／融合教育案（BVerfGE 96, 288 (301)）。另參見Osterloch (Fn. 29), § 3 Rn. 315.

47 BVerfGE 99, 341 (357)（民法有關身障者訂定遺囑要式性之規定）。

符合鐵路法（Allgemeines Eisenbahngesetz）授權訂定之鐵路興建及營運辦法（Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung, EBO）第2條第3項⁴⁸，乃依法提起確認訴訟，請求法院認定系爭營建計畫違反德國聯邦身心障礙者權益平等法第8條第2項規定。

系爭訴訟經曼海姆（Mannheim）行政法院認為系爭營建計畫並未違反鐵路興建及營運辦法之規定，判決原告敗訴⁴⁹，上訴後聯邦行政法院亦維持原裁判，原告敗訴確定⁵⁰。綜合兩項判決理由，大致可歸納為以下幾點：

1. 公益團體依德國聯邦身心障礙者權益平等法第13條所提之確認訴訟，性質與同法第12條身心障礙者自身之權利救濟不同，後者應屬於身障者本身之權利救濟，應提起撤銷之訴或課予義務之訴。法院於公益團體提起之確認訴訟中，無須審酌聯邦鐵路局作成核准處分時，是否就公益與私益已作適法衡量，是否充分考量利用該車站的身障者利益。就本案而言，法院所應審酌者，不是鐵路興建及營運辦法第2條第3項第2句至第6句系爭核准處分之合法性問題，而是同條項第1句：「本辦法規定之解釋與適用，應使身心障礙者、年長者、兒童及其他不便者能無障礙地使用車站設施及火車」如何適用問題，該句為本辦法其他法規解釋適用之指導原則，

48 鐵路興建及營運辦法第2條第3項規定翻譯如下：「本辦法規定之解釋與適用，應使身心障礙者、年長者、兒童及其他不便者能無障礙地使用車站設施及火車（第1句）。為達成前句所定目標，德國鐵路應訂定車站及火車無障礙設施設置計畫，使前句所定之人達到最大可能的無障礙利用（第2句）。無障礙環境設置計畫內容包括火車班次營運計畫，並應於每班次火車中公告週知（第3句）。設置計畫確定前，應給予經聯邦身心障礙者權益平等法第13條第2項規定認定之身心障礙權益團體之總會組織表示意見的機會（第4句）。德國鐵路應經由監督機關，將無障礙環境設置計畫提交至主管部會（第5句）。監督機關得許可例外不適用本項第2句、第3句之情形（第6句）」。

49 VGH Mannheim, 21. 04. 2005 – 5 S 1410/04 = BeckRS 2005, 27119 (27119 ff.).

50 BVerwG, 05. 04. 2006 – 9 C 1/05 = NVwZ 2006, 817 (817 ff.).

不能脫離該辦法其他規定，單獨視為車站所有相關設施應符合無障礙環境的規範基礎。

2. 從立法資料顯示，國會訂定鐵路法時，尚無意創設一般性的無障礙環境條款，而只將無障礙環境政策落實重點放置在歐洲跨國運輸點上的車站，並未及於德國境內所有車站；同樣地，德國聯邦身心障礙者權益平等法的立法過程資料亦顯示，立法者無意即刻造成鐵路營運者過重財政負擔，而是期待在身障者權益團體的參與下，就如何實施、期程如何與各鐵路公司及主管機關取得共識。再從鐵路法的授權子法鐵路興建及營運辦法第2條第3項之修正歷程觀之，1991年修正前，第1句原條文為：「本辦法規定之解釋與適用，應減輕身心障礙者……使用車站設施及火車所遇障礙」，其用語為使障礙「減輕」(erleichtert wird)，修正後現行條文用語為「使其能無障礙地利用」(ohne besondere Erschwerung ermöglicht wird)，此項修正凸顯政府部門有意落實身心障礙者無障礙環境政策，但修正理由卻未同時考慮所需經費。
3. 聯邦行政法院認為，鐵路興建及營運辦法第2條第3項第1句要求車站設施與火車須有無障礙設施，但並未具體要求應採取何種方式，依照同項第2句至第6句規定，落實方式係交由各鐵路公司於其營建計畫中規劃，「達到最大可能的無障礙利用」，並於聯邦鐵路局審查程序中賦予身障者權益團體參與表示意見的機會。就此而言，該條項第1句具有客觀目標設定的功能，其意味著，各鐵路公司於營建計畫中應將無障礙設施列為重大政策目標予以考量，至於如何落實無障礙環境之要求，享有一定的裁量空間，法院就此得依比例原則審查營建計畫是否確實符合該條項第1句所設定的目標。本案中基於財政負擔考量，德鐵公司以日旅客流量1000人次為準，作為舊有車站改建時，是否立即裝置月台電梯的標準，

新建車站的月台則一律裝設電梯。法院認為該項標準並未導致立法目的履行不足（Untermaßverbot），在財政負擔考量下，本難期待立即改善全德國所有車站月台設施，況且原告身障者權益團體並未爭執德鐵公司投入無障礙設施的經費是否過少。不過法院提醒，如果利用該車站的居民中有相當比例為辦法中所指之身心障礙者、年長者、兒童或其他行動不便者，則該1,000人次標準是否違反比例原則，即有討論空間。法院審查後認為，雖然系爭車站附近有一安養院收容的老人中有80%比例臥床或行動困難，其外出行動既需搭車，則可直接載至鄰近Aalen車站，利用大車站完善的無障礙設施上下火車。其餘身障者權益團體主張小站亦應設置月台無障礙設施以促進觀光及文化活動，法院認為理由尚不夠充分，不足以認定德鐵公司營建計畫違反比例原則。

4. 除上述理由外，曼海姆行政法院原審判決另從法律概念解釋的角度為小車站不設月台電梯解套：法院認為，綜觀系爭辦法第2條及其他規定，均未明確規定月台出入口應有如何之無障礙設施，例如第11條規定鐵道與道路交叉口路面應齊平，第13條規定新建（Neubau）或大幅改建（umfassender Umbau）時應符合之月台高度、旅客月台寬度、月台通道至軌道距離、貨運月台坡道等，這些條文均未提及旅客上下月台的無障礙環境，因此德鐵公司未於小站月台設置電梯，並未牴觸系爭辦法。
5. 綜合曼海姆行政法院及聯邦行政法院的看法，基於鐵路興建及營運辦法第2條第3項第1句規定限縮解釋的立場，鐵路興建及營運辦法並無要求月台出入須設置無障礙設施，德鐵公司該項交通設施並未違反聯邦相關法令規定而符合無障礙規範，系爭營建計畫不生牴觸德國聯邦身心障礙者權益平等法第8條規定之疑義。

附帶說明者，上開身障者權益團體曾就本件爭議聲請暫時停止執行營建計畫，曼海姆行政法院認為，公益團體並非身心障礙者本人，不能提起撤銷或課予義務訴訟，身心障礙團體依照德國聯邦身心障礙者權益平等法第13條所提之公益訴訟僅限於確認訴訟性質，系爭營建計畫是否實施與團體之權利無涉，此項聲請不符法定要件而裁定駁回⁵¹。在另一件同樣涉及車站改建工程的行政訴訟中，法院同樣以訴訟要件不符而駁回，這件訴訟係由車站改建工程所在地之巴伐利亞邦某鄉鎮市長，針對其轄區內車站改建計畫同樣未於月台設置電梯，以不符無障礙環境法令，且侵害其自治權、使其無法履行法定義務，讓所有居民都享有同等通行權利為由，向行政法院提起訴訟，請求撤銷原處分，聯邦鐵路局應另為適法處分。慕尼黑行政法院認為，身心障礙者能否無障礙使用火車站設施，並不屬於地方自治團體的自治權限範圍，巴伐利亞邦鐵路之興建、營運屬於邦之權限，亦與該鄉鎮市無關；再者，個別身障者使用車站的不便，並不直接等同於其所居住的鄉鎮自治團體權利受到侵害，該鄉鎮自己的權利或地方自治權並未因此受損，同樣以要件不符駁回該訴訟⁵²。從這兩件車站月台無障礙設施衍生之相關訴訟，應能凸顯出確認訴訟之功能並不在於權利救濟，與傳統撤銷訴訟或課予義務訴訟不同，這也是公益團體確認訴訟的功能限制所在。

三、以個人主觀權利為出發點的無障礙環境訴訟

除公益訴訟外，尚未見個別身心障礙者提起訴訟救濟之重要案例。不過，曾有非身障者就車行隧道缺乏充分設備，於發生意外時不能即時救援行動不便身障者為由，向行政法院提起撤銷隧道興建計畫決議之訴訟，經巴登符騰堡邦（Baden-Württemberg）高等行政法院以原告非身心障礙者欠缺訴訟權能而予以駁回⁵³；另有依賴

51 VGH Mannheim, 6. 12. 2004 – 5 S 1704/04 = NVwZ-RR 2005, 635 (635 ff.).

52 VGH Bayern, 16. 03. 2011 – 22 A 09.40041 = BeckRS 2011, 49357 (49357 ff.).

53 VGH Baden-Württemberg, 24.03.2010 – 12 S 515/09.

輪椅行動之身障者請求主管機關移除石磚路面，其死後由配偶承繼訴訟，法院以輪椅身障者的需求與權利具有一身專屬性，無從被承繼，該配偶缺乏訴訟權能而駁回該訴訟⁵⁴。學者由此推論，公益訴訟之外，個別身障者如能從營建法、道路管理法規等推導出身障者對其住所周遭公共設施之利用權利，應可認其具有訴訟權能，而得以個別權利主體之地位提起行政訴訟⁵⁵。

四、德國聯邦身心障礙者權益平等法實踐經驗之檢討

從德國基本法第3條第3項第2句之修憲，到身心障礙法制變遷歷程，再到無障礙環境訴訟實踐結果顯示，德國憲法法院法官雖然肯認身心障礙者依照憲法規定，享有衍生性的請求權，得享有公平參與社會的權利，立法者也將此意旨立法加以落實，明文聯邦政府就其管理之公共設施負有設置無障礙環境之義務，甚至賦予公益團體提起確認訴訟的權能，但以訴訟途徑監督政府履行無障礙環境設置義務仍有相當之難度，其癥結何在？此種立法例對於無障礙環境之實現，究竟提供何種幫助，又有哪些侷限性？

首先最值得肯定的是，該法於個人訴訟之外肯認公益訴訟途徑，突破保護規範說之限制，開啟以司法訴訟落實無障礙環境的途徑。同時，該法也在訴訟程序中賦予身障者權益團體非常重要的角色，一方面它們可於個人訴訟程序中代理身心障礙者提起訴訟或參加訴訟，以協助個別身心障礙者主張權益能力的不足；另一方面，它們得獨立提起公益訴訟，請求法院確認行政機關是否履行其法定無障礙環境義務。從實踐經驗而言，身障者權益團體提起的公益訴訟的確較個人訴訟更能發揮功能，促使法院必須檢視公部門是否依法落實無障礙環境設置義務，不過不可否認的是，德國法制上將公益訴訟類型限定在確認之訴，即便司法判決確認公部門未依法落實

⁵⁴ VG Aachen, 19.05.2009 – 2K 1903/08 = BeckRS 2009, 34657 (34657 ff.).

⁵⁵ Welti (Fn. 29), S. 725 (728).

無障礙環境的設置義務，身心障礙者個人之權益並不因此獲得回復、賠償或補償，仍待公部門改善欠缺之設施。

立法創設了公益訴訟途徑之後，法院已無保護規範說作為屏障，藉以迴避司法審查，那麼法官如何權衡身心障礙者權益與其他權利主體之利益或公共利益之間的輕重，亦將受到檢視與評價。以歐洲受迫害猶太人紀念碑案而言，法院在幾項互相衝突的利益之間進行衡量，包括聯邦政府透過紀念館所欲傳達予公眾的意念、設計者藝術表達自由與身障者無障礙使用該公共設施，也具體考量依照目前紀念館全區的設計，使用電動輪椅的身障者是否仍能夠如同一般常人體會到該項公共設施所欲傳達的孤立感受。從該項判決結果以觀，無障礙環境與身心障礙者的社會參與權利雖非絕對優先利益，但至少法院嘗試從電動輪椅使用者的角度出發，以其社會參與程度為量尺，不是簡單、抽象地衡量藝術自由與社會參與孰輕孰重，而是檢視公部門是否設法以其他媒介讓電動輪椅使用者即便不能直接進入到水泥柱矩陣的最深層，也能夠體會到設計者所欲傳達的理念，例如以影像等方式讓身障者身歷其境。

相對地，在德鐵公司月台無障礙設施一案中，法院似乎將利益衡量重點放置在政府財政負擔，而非身障者對無障礙環境的需求，而且將其包裹、隱藏在條文的解釋適用當中。曼海姆行政法院斤斤計較於條文用語，認為車站月台不屬於該辦法明文要求設置無障礙設施之範圍；聯邦行政法院則開宗明義區分公益團體提起確認訴訟與身心障礙者本人提起撤銷訴訟或課予義務訴訟二者功能不同，在公益訴訟之下，法院並不審酌系爭處分是否充分考量身心障礙者對無障礙環境之需求、是否有裁量瑕疵，而是抽象解釋鐵路興建及營運辦法第2條第3項規定究竟加諸鐵路公司多少程度的無障礙環境設置義務。德國聯邦行政法院不僅肯認公部門落實無障礙環境的裁量空間，更明確指出，立法當時既未充分考量財政負擔，所以在執行上以車站旅客人次為無障礙設施配置標準，仍符合該辦法之立法目

的。此種見解仍不脫財政配置以滿足多數人需求為優先，行有餘力始照顧身障者的邏輯。如果法院普遍持此見解，未曾真正理解身障者的需求，即便允許身障者權益團體提起公益訴訟，亦難獲得確認違法之判決。

五、德國法制對於我國法制借鏡之意義

依據上述分析與討論，德國聯邦身心障礙者權益平等法之立法例是否值得我國借鏡，大致可分為以下四個層次加以說明。

（一）公法權利、訴訟權能之推演與創設

在我國目前行政訴訟制度之下，由身心障礙者提起訴訟促使政府改善無障礙環境，首先將必須說服法院肯認相關無障礙設施規定有賦予其公法權利之意旨，在此不僅涉及身權法相關條文之解釋問題，也涉及公物利用本身究竟為利用人之權利或反射利益，尤其與身障者日常生活無緊密連結、未能形成依賴關係的公共設施如體育館、展覽場、音樂廳、博物館等，即使依據最為寬鬆的學理判斷標準，仍難認定人民享有利用之公法權利。如能引進德國聯邦身心障礙者權益平等法賦予公益團體獨立提起確認訴訟的規定，即可突破保護規範說以及公物利用僅為反射利益之限制，不過依照我國行政訴訟法第9條之規定，人民為維護公益，對於行政機關之違法行為提起行政訴訟，以法律有特別規定者為限，因此需要透過身權法或其他相關法律之修正，才能創設此種訴訟途徑。在立法例上，德國聯邦身心障礙者權益平等法第13條一一臚列公益團體可以針對政府違反哪些聯邦法令無障礙規定提起公益訴訟，我國身權法則可於第五章支持性服務中，針對政府是否落實無障礙環境之規定，增列公益訴訟的救濟途徑。

此種權益保障模式對我國而言並不陌生。2007年全文修正之精神衛生法第42條第5項規定：「經中央主管機關認可之病人權益促進

相關公益團體，得就強制治療、緊急安置進行個案監督及查核；其發現不妥情事時，應即通知各該主管機關採取改善措施，並得基於嚴重病人最佳利益之考量，準用第三項規定，向法院聲請裁定停止緊急安置或強制住院」，同法第45條第4項規定：「經中央主管機關認可之病人權益促進相關公益團體，得就強制社區治療進行個案監督及查核；其發現不妥情事時，應即通知各該主管機關採取改善措施」。依照上述兩項條文，此類經認可之精神病人權益促進公益團體依法享有獨立之訴訟權能，得為受強制治療精神病人之最佳利益，向法院聲請裁定停止緊急安置或強制住院。有意透過訴訟途徑監督政府是否確實落實無障礙環境設置義務的論者，應可採納德國立法模式，賦予身心障礙者團體公益訴訟之權能，以突破保護規範說之限制。引進公益訴訟的另項功能是，國內有諸多公共設施即便已依法設置無障礙設施卻遭違法佔用、阻礙，執法單位亦未積極取締之情形，此時所應適用之法律可能是道路交通管理處罰條例、各地方政府制定之自治條例或其他公有公共設施管理之相關法令，而非直接適用身權法之無障礙環境規定。如由身心障礙者提起課予義務訴訟，請求行政機關執行公權力，原告欲證立其有公法權利非僅止於反射利益會更加困難，如能以公益訴訟突破此項門檻，將有助於督促行政部門更為全面落實憲法保障建構無障礙環境之意旨。

在尚未修法之前，我國行政法院雖已否定依據保護規範說得以推導出身權法賦予身障者請求設置無障礙環境之公法權利，但說理相當薄弱，應有充實保護規範說之內涵、尋求突破的空間。就此，本文已於「參、一」及「參、二」等段落依照憲法解釋及相關學理，分析身權法第53條規定各級交通主管機關應依實際需求，規劃適當路線、班次、客車廂提供無障礙運輸服務，第54條市區道路、人行道及騎樓，應符合中央目的事業主管機關所規定之無障礙相關法規，第57條第3項各級目的事業主管機關應令公共建築物及活動場所之所有權人或管理機關負責人設置、改善無障礙設備及設施等

各條文，配合身權法第16條第2項之規定：「公共設施場所營運者，不得使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利」併同觀察，確屬保護規範，保護對象為因障礙環境而參與社會平等機會受阻的身心障礙者，其應具有請求主管機關依照身權法上開規定作為之公法上權利。

如果從公物利用觀點，擔心上述解釋所承認的公法權利範圍可能過廣，則可先借鏡學者提出之「是否建立依賴關係」判準適度限縮。以前述桃園縣身障居民請求縣政府及交通部公路局限制客運業者使用遊覽車營運為例，原告如針對其住家附近經常搭乘之客運路線，外出均仰賴特定路線公車，應可認為該身障者具有公法上權利及訴訟權能，得請求交通主管機關履行其基於身權法第53條、大眾運輸工具無障礙設施設置辦法第7條而生之作為義務，督促營運這幾條特定路線公車業者提供低底盤公車。至於校園建物設施之利用，身障者是否有依賴利用關係，可能須視情形而有不同認定：義務教育涉及學生受憲法保障之受義務教育權利，高中以上就學中學生之受教育權則受憲法第22條保障，校園是否提供無障礙環境，涉及到身障生學習、選課、校園生活參與等受教育權是否受平等對待，其對學校設施之利用應具有依賴關係，此時依照保護規範說以及公物利用之法理，應可解釋身權法第16條第2項、第27條第2項、第30條等規定有賦予身障學生公法權利，請求公立學校設置或請求教育主管機關命私立學校設置無障礙設施之意旨；其他未明顯建立依賴關係之情形，如前述高雄縣鳳山市身障居民請求排除住家附近國小、體育館等出入口障礙之案例，可能需要未來立法增訂公益團體訴訟條款來突破公法權利與反射利益之爭議。

特別值得注意的是，立法院甫於2014年8月1日通過身心障礙者權利公約施行法（以下簡稱「身障權利公約施行法」），將於同年12月3日生效。施行法第8條第1項規定：「身心障礙者受公約及其有關法規保障之權益遭受侵害、無法或難以實施者，得依法提起訴願、

訴訟或其他救濟管道主張權利；侵害之權益係屬其他我國已批准或加入之國際公約及其有關法規保障者，亦同」。該條規定是否足以突破保護規範說或公物利用關係之限制，留待下一節一併說明。

（二）訴訟類型

德國聯邦身心障礙者權益平等法中，身障者個人訴訟與身障者權益團體公益訴訟並存，前者未限定訴訟類型，但須以原告有公法上權利、訴訟權能為前提，後者無須審究公法權利之存否，但訴訟類型限定在確認訴訟。猶太人紀念碑案所確認者，係柏林邦政府依柏林邦營建法之例外規定，許可設計者免除部分無障礙環境的行政處分是否適法；德鐵公司月台改建案所確認者，係鐵路改建計畫之內容是否符合鐵路興建及營運辦法。我國公益訴訟之類型，並未限定於確認訴訟，端視公益團體請求內容加以區分，撤銷訴訟、課予義務訴訟、確認訴訟或給付訴訟均有可能⁵⁶，因此公益訴訟所得提起之訴訟類型是否限定於確認訴訟，乃是立法政策問題。再者，德國聯邦身心障礙者權益平等法第13條係確認公權力主體之行為是否符合無障礙環境之法令，也與我國行政訴訟法第6條規定之確認訴訟僅在確認行政處分無效及公法上法律關係成立或不成立不同。如果未來引入公益訴訟，且法政策上不限於確認訴訟類型，自無須另行增訂公益確認訴訟之標的，因為身心障礙公益團體提起撤銷之訴、課予義務之訴或給付之訴時，法院即須審究行政機關之行為或不行為是否適法。

（三）無障礙環境訴訟之實體審查

訴訟權能的問題如能透過保護規範說之解釋或立法增訂公益團體訴訟權能獲得解決，法院將無法迴避實質審查，必須就行政機關是否確已落實身權法第53條、第54條及第57條賦予行政機關之作為

⁵⁶ 陳清秀（註11），頁159-161。

義務、是否已為合義務之裁量，提出論理。

在「請求排除障礙環境」訴訟中，高雄高等行政法院判決之若干段落顯示，法院在一般民眾使用校園安全與身障者利用設施權益二者之間加以衡量，進行實質審查，認為三間國小所為之校門管理措施尚屬適當，前者較為優先；惟其理由為何，判決中並無具體充分的論理，法官可能亦未實地勘查現場，逕以一般常人感受作出判斷而未能體會身障者遭遇的障礙，那麼所謂的利益衡量恐怕也只流於文字上的形式論述而已。最高行政法院則擔心如由法院作此判斷，可能侵害行政機關之依法規劃、執行預算之權限，國內亦有學者提醒，基於權力分立原則，如相關規定僅賦予行政機關配置有限資源的權限，司法機關並不宜代為決定⁵⁷，基於此項立場，自然傾向行政機關就無障礙環境的落實方式、期程有其裁量空間，不宜由司法判決強制行政機關必須於某一時點、採取特定方式執行，對行政措施之合法性自然只進行低密度審查，尊重行政機關的決定⁵⁸。對照德鐵公司月台改建案，德國行政法院同樣以立法時政府未通盤考量財政負擔為由，認為系爭改建計畫未全面改善各火車站月台無障礙設施並未牴觸鐵路興建及營運辦法之無障礙環境規範。由此顯示，無論德國或我國行政法院，在無障礙環境訴訟中所採取的審查觀點，從未脫離財政負擔優先考量的立場。

在此值得進一步追問的是，難道法院進行合適性審查時，不應考量政府財政負擔問題？觀察上述我國與德國審判實務見解，恐怕問題不在「應否」，毋寧法院向來考量並尊重公部門的既有執法與預算配置計畫，人民欲透過訴訟制度挑戰其合法性，本有其難度，即便在釋憲實務中，身心障礙者長期以來也是「不被看見」的。司

57 國內有關保護規範說應否調整之討論，即有是否造成司法過度干預行政、造成三權分立關係傾斜之憂慮。參見林明昕，撤銷訴訟及撤銷訴訟之訴訟權能，法學講座，創刊號，頁89（2002年）；陳柏霖（註14），頁137-143。

58 陳柏霖（註14），頁161-164。

法院釋字第290號解釋中，大法官僅就動員戡亂時期公職人員選舉罷免法限制候選人學經歷之規定是否違憲加以解釋，其申請人劉俠女士係因缺乏無障礙設施無法就學、因而學歷不足無法從政的事實是不被考慮的，至於大法官於解釋理由書提到，各級民意代表候選人學經歷之限制是否有維持之必要，應「斟酌就學有實際困難之人士（例如因身體或其他原因其接受學校教育顯較一般國民有難於克服之障礙者），由立法機關為合理之裁量」，推測係因劉俠女士文壇聲譽卓著，受到社會尊重，才促使大法官略加著墨當時身障者學歷普遍不足的現象。而後在司法院釋字第417號解釋中，身心障礙者被「看見」了，但其無法使用天橋地下道、直接穿越馬路而違反道路交通管理處罰條例之情形，被視為應否免罰的個案問題。直到釋字第649號解釋視障按摩保留條款合憲性問題，大法官才「看見」了身障者的「社經處境」，也揭示了憲法增修條文第10條第7項扶助身障者自立為特別重要之公共利益。不過在這號解釋中，大法官對於身障者平等參與社會的可能性似乎又過於樂觀，以致於未能深入分析法制及社會條件對身障者形成的障礙環境⁵⁹。

在這樣的視野限制下，自難期待法院設身處地從身心障礙者的角度，探究公部門怠於落實無障礙環境，是否的確導因於財政困難，即便有困難，是否擬定計畫逐步落實化、有無裁量濫用之情形存在；對於法官而言，身心障礙者面臨的障礙環境，仍屬法律概念之抽象解釋，而非真實存在的權利行使障礙。即便憲法增修條文已明文國家應保障身心障礙者參與社會之權利，觀察我國司法院釋字第626號及第649號解釋的論理過程，大法官對於身體有缺陷者參與社會的平等權利，與非身障者的職業選擇自由或大學自治、國家資源有效配置等公共利益，並未給予同等程度的重視，更遑論是否因憲法明文而能取得較為優勢的利益衡量地位。或許法院在權力分立

59 詳見孫迺翊（註1），頁70-97。

的考量下，對於人民提起訴訟要求法院認定行政機關未履行法定義務，或要求命行政機關為改善行為、命行政機關要求民間單位改善等訴求，必然採取謹慎保守態度。因此，無障礙環境的落實，必須從立法與司法同時著手，立法文字的精確程度便成為訴求能否成立的關鍵之一，立法文字越精確，表示立法者的資源配置或身障者與第三人利益間的權衡決定越明確，法院得據以判斷行政行為違法性的基準就越為明確⁶⁰。

（四）身障者權益團體之程序參與

此外值得注意的是，德國聯邦身心障礙者權益平等法設有身心障礙者權益監察人，讓身心障礙者權益能及早於各項政策形成過程中受到充分考量，落實身心障礙者權益主流化，減少日後產生爭議；鐵路興建及營運辦法第2條第3項則特別規定，各鐵路公司於無障礙環境設置計畫確定前，應給予身障者權益團體表示意見的機會，其目的在於希望政府、各鐵路公司與身障者權益團體能就設置內容與時程，在考量財政可負擔性的前提下務實地達成共識。我國身權法亦有相近規定，該法第53條第1項：「各級交通主管機關應依實際需求，邀集相關身心障礙者團體代表、當地運輸營運者及該管社政主管機關共同研商，於運輸營運者所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車（機船）廂（艙），提供無障礙運輸服務」之規定，明文賦予身心障礙者團體參與法規命令訂定之參與地位，未來如能修法配合身心障礙者團體獨立提起公益訴訟之權能，應更能發揮監督政府履行身權法義務的功能。

60 建築法第97條授權訂定之建築技術規則建築設計施工編第十章「無障礙建築物」，及建築物無障礙設計規範已有非常具體之技術規範，得為法院判斷公有公共建築物設置是否適法之標準，不過宜於法律層次明文規定公、民營單位有設置無障礙環境之義務。

伍、國際人權公約與憲法增修條文第10條第7項 無障礙環境條款之內涵補充

綜上說明，我國憲法增修條文第10條第7項明文要求國家應落實無障礙環境，但此項基本國策條款在司法判決實務上未獲重視，且深入討論其意涵的法學文獻非常有限，以致未能提供法官解釋適用法律的價值指導功能。過去，大法官曾於司法院釋字第549號、第578號解釋要求立法者應參酌國際勞工相關公約之意旨修正相關法律，其論理方式是以國際人權法基本標準，補充國內學說實務對於憲法基本國策條款中社會安全制度內涵認知不足之處。我國立法院甫於2009年制定公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權利國際公約施行法，將兩公約內國法化，那麼兩公約對上開條款之解釋，是否能提供內涵補充的功能⁶¹？是否如李秉宏律師所言，必須將聯合國身心障礙者權利公約內國法化，才能提供貼近身障者人權的觀點？

一、一般性人權公約與身心障礙者人權

（一）公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權利國際公約

公民與政治權利國際公約規範國家應保障其國民之自由權與平等權，經濟社會文化權利國際公約則是規範締約國應落實勞動權、社會權及文化權保障，這兩項公約係以普世人權為圖像，其所強調的人人生而自由平等，乃是傳統「等者等之，不等者不等之」的形式平等（formal equality）概念，並未關注特定弱勢族群所面臨的實質平等（substantive equality）問題，亦未能更深一層關照到對象／

⁶¹ 有關經濟社會文化權利國際公約對我國基本國策中社會安全制度條款解釋之影響，參見孫迺翊，經濟社會文化權利國際公約與我國社會憲法之比較及其實踐——以社會保障權為例，收於：蘇宏達、陳淳文編，中國民國實施聯合國兩權利公約的意義：接軌國際，深化民主，頁181-191（2013年）。

事物「相同」(sameness)或「不同」(otherness)的形成背景脈絡；且公民與政治權利國際公約第2條、第26條以及經濟社會文化權利國際公約第2條明文禁止歧視之事由不包括身心障礙因素，凸顯公約訂定當時尚未意識到身心障礙者的人權議題⁶²。

而有關兩公約之一般性意見，在公民與政治權利國際公約方面，一共34則一般性意見並未針對身心障礙者是否平等享有自由權利之保障加以說明，第18號有關不歧視之一般性意見亦未特別論及身心障礙歧視問題；直到1994年經濟社會文化權利委員會通過經濟社會文化權利國際公約第5號一般性意見，才特別針對身心障礙者加以闡述，其中第22點、第23點提到充滿障礙的交通、住房、工作地點是造成身障者無法接受教育、職業培訓以及找到適合正常工作的原因，第5點至第7點要求締約國應盡最大可能利用所有資源，使身心障礙者在享受公約權利方面克服身心障礙帶來的種種不利因素。不過由於該公約訂定時缺乏明確與身心障礙者相關之條款，因此經濟社會文化權利委員會建議另行參酌國際社會相關人權文件，如1993年「身心障礙者機會均等標準規則」(Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities)等類國際軟法，第14點並要求締約國在制訂、執行相關政策時，應與有關人員團體的代表協商與參與⁶³。

62 Oddný Mjöll Arnardóttir, *A Future of Multidimensional Disadvantage Equality?*, in THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: EUROPEAN AND SCANDINAVIAN PERSPECTIVES 41, 47-49 (Oddný Mjöll Arnardóttir & Gerard Quinn eds., 2009).

63 兩公約之一般性意見文本，中譯文參見法務部，公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約——一般性意見（2012年）。See also Ida Elisabeth Koch, *From Invisibility to Indivisibility: The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, in THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: EUROPEAN AND SCANDINAVIAN PERSPECTIVES 67, 73-75 (Oddný Mjöll Arnardóttir & Gerard Quinn eds., 2009).

(二) 歐洲人權公約：以歐洲人權法院的無障礙環境訴訟為例

與聯合國兩公約同一時期，歐洲另有區域性人權公約，即歐洲人權公約（European Convention on Human Rights），它同樣標舉普世人權價值，保障形式平等，不過該公約設有歐洲人權法院，許多身障者乃嘗試透過此項途徑尋求突破⁶⁴，使得歐洲人權法院有機會針對締約國未能落實無障礙環境是否違反人權，有表示意見的機會。以下所介紹之歐洲法院判決，身障申請人均以無障礙設施不完備，主張被告國家政府之不作為已經抵觸歐洲人權公約第8條「人人有權要求尊重其私人及家庭生活，其住家及通信（第1項）。前項權利，於民主社會中所必要之範圍，因國家安全、公共安寧、國家經濟福利、防止動亂或犯罪、保護健康或道德或保障他人之權利及自由得依法限制之（第2項）」以及公約第14條歧視禁止條款⁶⁵。

上述公約第8條「保障私人生活」（private life）條款，主要在確保個人之人格及其與他人之接觸不受外在之干預，而所謂私人生

64 有關歐洲人權法院之職權、個別公民向歐洲人權法院提出申請案之要件，詳見廖福特，歐洲人權法院——歷史、組織、職權及程序，思與言，38卷4期，頁67-116（2000年）（以下簡稱：廖福特，歐洲人權法院）；廖福特，因為成功而改變，但是改革未完成——歐洲人權法院改革方案之分析，月旦法學雜誌，148期，頁57-77（2007年）（以下簡稱：廖福特，歐洲人權法院改革方案）。

65 除本文以下所介紹四個案例外，*Nikky Sentges v. Netherlands*案裁定（App. No. 27677/02, ECHR 2003，未收錄於裁判選集出版，裁定全文收載於歐洲人權法院裁判資料庫：<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-23318>（最後瀏覽日：2015年4月6日））亦與歐洲人權公約第8條有關，但該案並非直接涉及本文討論的公部門設置無障礙環境義務，故僅作以下簡介：該案荷蘭籍申請人Sentges患有一種名為DMD之重症，全身肌肉萎縮無力，需仰賴電動輪椅行動以及24小時看護。其父母於1999年向健康保險申請提供一種專為此類病患設計的電子手臂，可以協助患者諸多生活上的行動，該電子手臂要價高達36,000歐元，此項申請遭到荷蘭健保單位拒絕，因為該項設備並不在健保給付項目之列。歐洲人權法院同樣援引上述幾項案例確立之原則檢視申請人Sentges之主張，認為荷蘭政府已經透過健保制度以及特殊醫療支出法提供申請人各種給付，包括符合其需求之電動輪椅，似難認為荷蘭政府不提供電子手臂或負擔相關費用，即已逾越尊重私人生活之公約義務。基於上述理由，歐洲人權法院裁定不受理本案。

活指每個人自由發展實踐人格的範疇，包含個人與他人之往來，也涵蓋公共領域之往來，甚至公約所稱「尊重私人及家庭生活」，依照歐洲人權法院之見解，也包括一定程度建立與發展與他人關係之權利⁶⁶。此項條款原與無障礙環境毫無關連，不過身障者嘗試進一步擴張該條之保障意旨，使身障者因國家怠於設置無障礙設備而導致其行動自由或與他人交往自由受到阻礙，也能援引該條請求歐洲人權法院審酌國家之不作為是否違反公約義務。自1998年出現Botta案判決起，歐洲人權法院大抵援引該案所設立之原則審酌締約國無障礙環境不週是否牴觸公約之爭議，雖然為數不多，且身障者均告失敗，但可以讓我們明確瞭解一般性人權公約處理無障礙環境議題的侷限所在。

1. *Botta v. Italy* 案判決⁶⁷

Botta為一名使用輪椅之身心障礙者，他與另一位身心障礙者於1990年到義大利位於Comacchio之某處海灘度假，發現該處私人海灘並無斜坡道、特殊裝置之升降梯以及廁所，以致身障者無法如同常人一般到達海邊戲水。義大利於1989年即定有保障身心障礙者權益之法律，其規定國家有義務保障身心障礙者之權利與人格尊嚴，國家並應要求一般私人尊重身心障礙者，其中，政府授與私人經營海水浴場之契約必須包含設置無障礙設施之條文，並同意地方政府得據以執行公權力。1991年間Botta寫信給該海灘所在之地方政府及相關單位請求採取改善措施，經營海灘之公司回覆，稱授權經營契約中並無要求設置無障礙設施之條款；該海灘之地方主管機關另稱，必須要有官方正式的要求，才能批准設置無障礙設施；Comacchio市長則說，該海灘由私人經營，應由該私人設置無障礙

⁶⁶ 廖福特，國家積極義務與私人生活保障——歐洲人權法院2010年相關判決之檢視，台灣法學雜誌，180期，頁45-46（2011年）。

⁶⁷ Botta v. Italy, App. No. 21439/93, 24 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I.

設施。Botta乃對上述官員提起訴訟，主張這些官員未能督促私人業者改善無障礙設施，觸犯義大利刑法第328條廢弛職務（omitting to perform official duty）之罪。Botta於1992年就義大利政府之不作為，向歐洲人權法院尋求救濟，歐洲人權法院係以歐洲人權公約第8條「任何人之私人生活應受尊重」、及第14條「不受歧視享有公約保障之自由權」作為審查依據⁶⁸。

Botta主張其參與社會生活之權利，不是因為義大利政府之積極干預而受侵害，毋寧是因為政府消極不作為，而無法如常人般實現其正常的社會生活。在此涉及一個關鍵性問題：「私人生活保障」是否應擴張其保障範疇，從政府消極不侵犯個人之私人生活，擴張至政府應採取積極措施，有效尊重個人人格發展之自由？該項權利保障範疇，是否及於具有財政支出效果的社會給付？許多締約國均主張，其公約義務之履行須視其財政狀況而定，締約國應享有寬廣裁量空間決定採取何種措施來履行公約義務，義大利政府即抗辯，本案申請人所提政府應督促私人設置海灘無障礙環境之訴求，尚非公約第8條所欲保障之範疇。

關於Botta之訴求，歐洲人權委員會（European Commission of Human Rights）⁶⁹認為其已逾越歐洲人權公約第8條「尊重」、「私人生活」兩項法律文字之意涵範圍，其性質上毋寧較為貼近社會權，較適合以賦予締約國高度彈性的歐洲社會權憲章作為保障依據，且社會權涉及一國資源與財政支配，法院不適合依據公約第8條加以審酌，當然這並不表示國家得恣意決定並得以財政困難為由加以正當化。就此，歐洲人權法院首先明確表示，依據先前判例，「私人

68 本案在後續幾年當中，該地區幾家私人經營管理的海灘雖陸續改善電梯等設備，但截至1997年為止仍無任何一家度假海灘設置坡道使身障者能夠無障礙到達海邊，而Botta所造訪的私人海灘直到1997年才提出改善計畫，1999年才完成符合法令的無障礙設施。

69 有關歐洲人權法院受理案件之審理程序與組織變遷沿革，詳見廖福特，歐洲人權法院（註64），頁74-78。

生活」指個人不受干預地透過與他人之交往溝通而發展其人格⁷⁰，且該條不僅要求國家「不干預」之消極作為，更要求國家負有積極義務有效尊重人民之私人與家庭生活。不過所謂「尊重」，公約並未明確定義，法院在判斷締約國究竟負有何種尊重義務時，必須考量公共利益與個人利益之間的衡平，締約國就此所作決定雖應受尊重，仍有其界限。

歐洲人權法院認為，申請人向歐洲人權法院起訴時，其所訴求之國家應作為義務須與其私人生活之間具有直接關連性，方屬公約第8條「私人生活」之保障範疇，例如愛爾蘭之法律未提供人民有效法律扶助導致人民無法獲得訴訟救濟（*Airey v. Ireland*, 9 October 1979），荷蘭的刑事訴訟法未賦予精神障礙者充分有效的程序保障（*X and Y v. the Netherlands*, 26 March 1985），義大利政府未告知排放有毒物質工廠附近居民相關訊息，使其知悉一旦發生意外將直接暴露於危險之中，據以評估其個人及家人居住於此的風險多少（*Guerra and Others v. Italy*, 19 February 1998）等。惟本案中，法院認為Botta所主張者為無障礙接近海灘之權利，此項活動不在其居住地點日常生活周遭範圍之內，歐洲人權公約第8條「私人生活」之保障範圍尚未及於如此廣泛的範圍，而認為Botta的主張不在公約第8條保障範圍之內。至於公約第14條，受限於歐洲人權公約規定，不歧視原則必須與公約及公約議定書所保障之自由權利連結使用，Botta的主張既不屬於公約第8條範圍，歐洲人權法院亦無從檢視是否違反第14條平等原則，是以Botta之主張最終未能透過歐洲人權法院判決獲得救濟。

⁷⁰ 諸多判例中，法院特別援引*Niemeietz v. Germany*案，本案涉及檢察官搜索律師事務所檔案，檢閱其與當事人之間的文件，法院認為德國政府此項行為已經干涉申請人之「私人生活」。ALASTAIR MOWBRAY, *CASES AND MATERIALS ON THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS* 488-90 (3d ed. 2012).

2. *Marzari v. Italy* 案裁定⁷¹

義大利籍之Marzari罹患一種罕見疾病，病徵包括呼吸困難、喪失語言能力以及體溫失調，氣溫變化會帶來肌肉疼痛，只能依賴輪椅行動，自1980年被認定為100%失能。Marzari考量其需求，自1973年起自行租屋居住（第一住所），該處符合其生活需求。1988年當地住宅主管機關欲整修該棟建築，並為Marzari另行安排住所（第二住所），Marzari於1991年入住之後覺得該處不合其需求。接著1992年義大利通過一項法律，依其規定，住宅主管機關有義務提供完全失能者符合其需求的無障礙設備。Marzari隨即要求住宅主管機關應改善房屋設備，並於1993年起停止付房租直到改善為止；住宅主管機關催繳房租未果，1994年依法定程序取得法院裁定強制其搬遷。Marzari將汽油潑灑於該棟建築物周圍做為抗爭手段，但隨後被逮捕、判刑。接下來數年間搬遷之強制執行命令一再暫停，另一方面第二住所之設備環境也經該省健康服務部門認定確實不符Marzari之需求。1998年Marzari終究被安置於醫院，他的健康狀況因環境因素而惡化，並開始絕食作為抗議，醫生也認為該醫院缺乏相關設備，不適宜長期收容該名病患。政府相關單位開始積極為Marzari找尋適當的安置處所，經研究此項病症之專家評估後，政府選定一處公有住宅，作為安置處所（第三住所）。此項安排卻遭該名病患拒絕，堅持留在醫院，1999年醫院請求警察協助將該名病患強制驅離醫院。

在歐洲人權法院的訴訟程序中，原告詳細列出第三住所之缺失，主張第二住所比第三住所更符合其病徵需求，堅持回到第二住所，且第二住所自其被強制驅離之後並未配住給他人。法院延續上

⁷¹ *Marzari v. Italy*, App. No. 36448/97, ECHR 1999。本裁定未收錄於裁判選集出版，裁定全文收載於歐洲人權法院裁判資料庫，<http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-22827>（最後瀏覽日：2015年4月6日）。

一判決之見解，認為只有當原告主張政府應採取之措施與其私人生活之間有直接關連性時，方屬公約第8條私人生活條款之保障範疇。義大利政府將Marzari從第一住所強制驅離，該行為即屬對私人生活領域之干預，該驅離行為係因原告積欠房租，有其法律依據，且相關政府單位長期以來一直避免採取強制措施；相對地原告從未採取合作態度，就此而言義大利政府之驅離措施並未牴觸公約第8條私人生活保障條款。至於原告主張義大利政府未提供符合特殊需求之住宅，法院認為該國政府已經延請相關病歷專家為其選擇適合的安置處所，儘管原告主張第二住所較符合其需求，但地方政府依照專家建議所做決定並不在歐洲法院審酌範圍，且公約第8條並未要求義大利政府必須將原告安置於某一特定之住所，該處地方政府也願意持續改善第三住所之設備以符合原告之需求。就此而言，歐洲人權法院認為義大利政府已經履行公約之義務，而裁定不受理該案。

3. *Zehnalová and Zehnal v. the Czech Republic* 案裁定⁷²

Zehnalová為捷克人，亦為一身障者，居住於Přerov，其於1994年向當地政府申訴，指出該地區有許多開放給公眾使用的公共建築物如郵局、警察局、地方政府辦公處所、地區社會安全局、電影院、地方法院、律師事務所、多數診所、游泳池等均缺乏無障礙設施，不符建築法（*Building Act*）及相關法令之規定，身障者無法進入使用。按捷克建築法第59條與我國身權法第57條內容近似，其規定新建公共建築物如無無障礙設施，主管機關不得發給許可，此外另有法令詳細明訂建築物應符合之無障礙設施技術規範。地方首長回覆Zehnalová，表示市議會將組成小組，與身障者權益團體聯繫，共同檢視相關建築物並將採取改善措施，惟實際上並未積極辦

⁷² *Zehnalová and Zehnal v. the Czech Republic* (dec.), App. No. 38621/97, 38621/97, ECHR 2002-V.

理，Zehnalová乃向該國經濟事務部提起訴願，要求經濟部逕行檢視建築物之合法性，經濟事務部函覆Zehnalová表示本案將交由地方政府「依法辦理」，但未設定任何辦理期限。地方政府隨即檢查219棟建物，經濟部也針對Zehnalová所提出之建物名單加以檢視，惟考量經費及既有建築物的結構問題，缺失之改善無法一步到位，只能盡其可能採取相關措施，例如與私有建物所有人協商增設無障礙設備。Zehnalová認為地方政府仍未積極採取措施，乃向法院提起訴訟，地方法院認為原告之主張僅涉及公共利益事項，依法無從提起行政訴訟。Zehnalová提起上訴及憲法訴訟均告失敗，乃向歐洲人權法院尋求救濟，原告特別指出，其所列各項公共建築物均位於其居住之城市中，與其日常生活息息相關，與Botta案訴求度假地點之無障礙設施不同。

歐洲人權法院重申Botta案之立場，認為依據歐洲人權公約第8條之意旨，締約國負有積極尊重私人生活之義務，無論是消極不干預義務或積極作為義務，個人權利之保障必須與社會整體利益作一公平衡量，就此各國政府享有廣泛裁量空間。究竟歐洲人權公約第8條能否作為要求國家積極設置無障礙設施之依據？歐洲人權法院認為該條不足以作為身障者廣泛訴求締約國改善公共場所無障礙設施之依據，毋寧僅限於一定情境之下，亦即當缺乏某項公共建築物之無障礙設施，確實阻礙原告人格自由發展、限制其與他人或與世界交流，法院才能依據該條審酌締約國是否履行其公約義務。歐洲人權法院認為，本案原告所訴求之公共場所仍過於廣泛，並未具體指陳其日常生活中有何具體需求與使用各該公共建築物之間具有直接關連性（direct and immediate link），當國家未改善其無障礙設備時，原告之私人生活將遭受如何之阻礙，更何況本案中捷克政府也逐步採取改善措施。依據上述理由，歐洲人權法院再次裁定不予受理。

4. *Mólka v. Poland* 案裁定⁷³

申請人Mólka為波蘭公民，其因身心障礙因素須使用輪椅行動。1998年間Mólka住所所在地舉行市議會（municipal council）、區議會（district council）及省議會（provincial assemblies）之選舉，Mólka與母親至投票所投票，因輪椅無法進入投票場所而等待於外，其母親要求投票所主任應協助Mólka進入投票所，或允許將票帶至場外讓他圈選後由其母親代為投入票箱，投票所主任認為相關法律並不允許將票攜出投票所，亦不願協助Mólka入內，Mólka只好放棄投票返家。Mólka主張該國選舉選務機關不願提供無障礙設施或協助，無異剝奪其選舉權，向Nowy Sącz地方法院、Cracow上訴法院提起訴訟，他並明確主張，對於身障者而言，無障礙進入投票所的唯一方式，就是使用延伸坡道，如果由第三人將身障者抬入投票所，將使其感到窘迫、受阻。惟該國法院終局判決認為選務機關之處置並未違反該國地區選舉法（Local Election Act）之規定，而向歐洲人權法院尋求救濟。其中Nowy Sącz地方法院之見解非常「經典」，完全凸顯將障礙視為「個人因素」，必須自尋解決之道的傳統思維：

原告主張選務機關應提供使其能夠進入投票所之設施……，但是地方選舉法就此並無任何規定，要求選務機關必須負擔此項義務……。身障者在其私人生活及公共生活領域受到諸多限制，的確使其難以真正行使自由權利，但公權力主體並無消除所有障礙的義務，即便有波蘭憲法、歐洲人權公約…等規範，亦不表示法律有加諸政府消除障礙義務之意旨。原告自知其身體障礙，他負有一項特殊的義務（special duty）：他必須認知自己的權利以及選舉法上的限制。……如果原告事先瞭解選舉法之規定，他就應該

⁷³ *Mólka v. Poland* (dec.), App. No. 56550/00, ECHR 2006-IV.

預先商請第三人協助，使其能夠進入投票所投票……。身心障礙本身就代表著限制所在，原告認為由旁人協助抬入會使他感到窘迫，這樣的說法尚不足以作為他無法投票的正當理由……。

本案雖因投票所缺乏無障礙設施，導致身障者無法行使其投票權，但令人訝異的是，歐洲人權法院認為本案事實不屬於歐洲人權公約第一議定書第3條保障人民依其自由意願參與立法機關選舉之範疇，因為依照波蘭之政府體制，其屬單一國，從該國憲法及法律規定，上開各級政府議會並不具有公約該條意義下之立法權。在此前提下，歐洲人權法院仍舊以公約第8條作為審酌之依據。法院認知到，身心障礙者欲享有公約保障之各項權利，亟需國家積極採取各種措施。在*Botta*案及*Zehnalová and Zehnal*案中訴訟失敗的原因是，申請人主張的無障礙設施對其私人生活究竟有何具體不利影響並不明確；相對地，在本案中，申請人訴求之無障礙設施與其參與社會生活權利之間具有相當顯著關連性。接著歐洲人權法院筆鋒一轉採取了尊重締約國的立場：依照公約第8條之意旨，締約國固然應採取積極作為「尊重」人民私人生活，惟個人之利益仍須與整體社會公益取得衡平，締約國對此享有相當寬廣的裁量空間，究竟一國有多少資源能夠投注於無障礙設施，各該國家政府較諸國際法院更適合作判斷。原告*Mólka*雖然主張如由第三人來協助他進入投票所將使其感到窘迫，惟波蘭地方選舉法第46條的確僅規定身心障礙者得由第三人協助其投票，而未規定應由選務機關提供協助；法院認為本案僅是單一個案，尚不足以證明波蘭政府怠於作為而使身障者參與社會之權利普遍受到阻礙。法院亦注意到，波蘭於1995年制定建築法，要求公共建築物必須有無障礙設施，接著2001年該國國會選舉法生效，要求相關機關應提供無障礙設施使身障者能夠行使國會議員選舉之投票權，這些立法均顯示波蘭政府並無意阻礙身障者行使投票權。基於上述理由，歐洲人權法院仍裁定不受理本案。

（三）小結

上述判決顯示，即便歐洲人權法院嘗試擴張歐洲人權公約第8條私人生活保障條款之適用範疇，藉以審視締約國身障者因障礙環境而無法享有自由權的問題，但一般性人權公約終究難以提供適當的分析論述觀點。一方面是因為歐洲人權法院相當謹慎，在擴張私人生活保障條款適用範圍的同時，也限定國家應採取而未採取之無障礙措施必須與私人生活受限，亦即身障者人格發展自由權利因此無法發揮具有實質關連性，上述案例所呈現的私人生活關連性，因身障者的訴求內容而有疏密之別：相較於*Botta*案訴求遠離住家的度假地點無障礙環境，*Zehnalová and Zehnal*案訴求住所所在地城鎮各項公共場所建築物的無障礙環境相對具體一些，但與申請人個人生活領域之緊密關連程度似乎尚有不足；相對於此，*Marzari*要求配住無障礙住所及*Mólka*主張投票所應設斜坡道使輪椅族能自行進入行使投票權，分別與身障者之自立生活及參與社會生活之權利有直接、密切的關連性。

依*Botta*案所確立的原則，身障者如能證立二者的直接關連性，似乎即有可能以締約國違反公約第8條之保障申請歐洲人權法院審理⁷⁴。不過，在關連性最為明確的*Mólka*案中，歐洲人權法院最終仍然採取尊重被告國家之立場，且波蘭內國法院將克服障礙環境歸諸於身障者之義務、要求身障者必須自行設法解決的見解，並未受到歐洲人權法院的指正，波蘭地方選舉法第46條之妥適性亦未受到檢討，歐洲人權法院甚至以個案視之，並以事後建築法等相關法令已獲修正認定波蘭政府無意阻礙身障者行使其自由權利。這些在在顯示一般人權法對於締約國有無設置無障礙環境之議題，論理上的貢獻十分有限。由此應可推知，何以經濟社會文化權利委員會於經濟社會文化權利國際公約第5號一般性意見中，建議另行參照身心

⁷⁴ MOWBRAY, *supra* note 70, at 582.

障礙者權益相關之國際軟法文件，來檢視締約國是否已盡最大可能利用所有資源，克服各種障礙環境，使身心障礙者能公平享有公約權利，而這些國際軟法文件，即為2006年聯合國身心障礙者權利公約的前身⁷⁵。

二、身心障礙者權利公約內國法化對於我國無障礙環境訴訟之意義

聯合國身心障礙者權利公約（以下簡稱「身障權利公約」）是以身心障礙者面臨的障礙環境為出發點，先理解障礙來自多面向、結構性的歧視與不平等，再逐一針對公民與政治權利、經濟、社會、文化等各項權利，要求締約國應排除身心障礙者行使權利的障礙，使身心障礙者能無障礙地與他人往來，並將此項核心概念整合在公約第9條。整部公約並未另行創設新的人權，而是要求締約國應促進、保障、確保身障者具有與常人一般行使普世人權的公平基礎，能夠參與社會、融入社會，其立論基礎在於社會模式／人權觀點，為達此目的，無論是身障者身體不受侵犯的權利、自由言論表達的權利，或是選擇工作、接受教育的權利，不分自由權或社會權都需要締約國投注資源積極作為，不同於公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約之區隔⁷⁶。

該項公約於2014年12月3日隨著我國身障權利公約施行法之生效而成為內國法之一部分，施行法第10條第1項及第3項規定，各級政府機關應徵詢身障者權益團體之意見，於本法施行後二年內就其主管法規及行政措施提出優先檢視清單，施行後三年內完成法規之增修、廢止及行政措施之改進，並應於施行後五年內，完成其餘法

75 Michael Ashley Stein & Janet E. Lord, *Future Prospects for the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, in THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES: EUROPEAN AND SCANDINAVIAN PERSPECTIVES 17, 21-23 (Oddný Mjöll Arnardóttir & Gerard Quinn eds., 2009).

76 *Id.* at 23-31; Koch, *supra* note 63, at 73-76.

規之訂定、修正或廢止及行政措施之改進；法規增修、廢止或行政措施改進之前，同條第2項明文，必須優先適用公約之規定。準此，政府負有法定義務，必須全面檢視我國各項法令是否提供身障者無障礙環境，而不僅侷限於身權法之規定，亦不僅限於臚列究竟提供身障者多少社會給付，而是要全面檢討身障者是否享有與非身障者相同的自由權行使機會。

聯合國身心障礙者權利委員會（Committee on the Rights of Persons with Disabilities）甫於2014年4月11日公布第1號及第2號一般性意見，前者針對公約第12條法律上平等，後者針對公約第9條「無障礙」作出解釋。第2號一般性意見第15點要求，供公眾使用之新設備應符合「通用設計」（universal design）的概念，例如無障礙道路、低底盤公車等；第17點要求締約國應消除建築、道路、交通、室內外設施，包括學校、住房、醫療設施和工作場所，以及資訊接收傳遞、通訊及其他服務諸如電子服務或緊急服務等各種障礙；第24點要求締約國針對舊有設施之改善，必須擬定合理時程予以落實；第29點則要求締約國必須將「無障礙主流化」的概念落實於各種領域的法律⁷⁷。在落實方法上，第2號一般性意見第28點要求締約國應與身障者權益團體代表及建築、都市計畫、設計規劃等相關領域學者專家進行協商，制定無障礙標準的法律框架；第29點指出，身障者如無法進出向公眾開放的設施、交通，或取得資訊和通信或服務，均應可以獲得有效的法律救濟。目前已有一例向委員會申訴的個案出現，身心障礙者權利委員會認為，被申訴的締約國

⁷⁷ 本公約第2條第2項及第4項將「拒絕提供合理便利措施」（reasonable recommendation）定義為一種歧視形式，而合理便利措施是指依照具體情形，在不造成過度負擔的情形下，依照身障者的需要進行必要的適當修改或調整。此項定義將擴張歧視與平等的概念，一般性意見第2到第25點區分無障礙與合理調整，前者是針對潛在及既有的身心障礙者群體所採取的事前措施，後者是針對個別身障者、事後遭遇障礙時所採取的調整措施，這點留待未來他文再作討論。

匈牙利應確保所有提供給公眾的服務均應有無障礙設施，包括確保視障者亦能使用提款機⁷⁸。依此標準，前述幾項歐洲人權法院判決所涉案例如有機會另透過個案申訴制度交由聯合國身心障礙者權利委員會審查，應有截然不同的審查結果。

我國雖已建立相對完善的各項權利救濟途徑，惟面對公部門未落實無障礙環境之規定，身障者欲尋求司法救濟仍有重重困難，已如上所分析。有鑑於此，身障權利公約施行法第8條第1項特別明文規定，身心障礙者受公約及其有關法規保障之權益遭受侵害、「無法」或「難以實施者」，得依法提起訴願、訴訟或其他救濟管道主張權利。此項規定為其他幾項公約之施行法所無，立法者顯然有意突破現行權利救濟制度之限制，無待訴願法與訴訟法之修正，讓身心障礙者本人自施行法生效時起，即能透過司法救濟途徑主張公約所保障之權利。在無障礙環境訴訟上，此項規定是否能夠真正突破公法權利與反射利益之區分，尤其在權利「無法」或「難以」施行之案例類型，行政法院對於該條之解釋適用，是否因身障者提起之訴訟類型為撤銷訴訟、課予義務訴訟、給付訴訟或確認訴訟而有差異，仍待觀察，但從立法意旨而言，的確已為身障者移除第一道權利救濟障礙。

以前述校園欠缺無障礙環境為例，假設身障學生援引身障權利公約施行法第8條提起給付訴訟，要求其所就讀之國立大學應於一定期間內逐步改善校園障礙建築物與廁所，改善期間應提供替代措施協助身障學生上下課及住宿生活，推測我國行政法院可能依照身權法第32條第3項，高中以上學校提供身心障礙者無障礙設施「得」向中央教育主管機關「申請補助」之規定，認為學校並無設置義務，身障學生亦無從請求主管機關命學校設置；甚至可能援引

78 Szilvia Nyusti, Péter Takács and Tamás Fazekas v. Hungary (communication No. 1/2010).

司法院釋字第626號解釋，認為基於大學自治，學校得於簡章自訂招生要件，選取適合該學系的學生，或主張其於各系所之招生簡章上已經註明視障、肢障、聽障學生「宜慎重考慮」是否就讀，既然選擇就讀，就表示該身障學生經過評估可以自行解決障礙問題。面對此種「合理差別待遇」的主張或「柔性阻擋」的作法，法院的論證與判斷結果為何，端視法官對於國際身障者人權法上社會模式／人權觀點等新觀念、對於憲法增修條文及身權法相關規定的認知有多少。須知，正是因為身心障礙者平等參與社會的權利相較於政府財政負擔等公共利益或其他非身障者之權利，向來處於利益衡量天平上的絕對弱勢地位，憲法及身障權利公約才明文賦予國家保障與落實之義務，也因此，施行法第8條第3項規定，政府應對司法人員辦理相關訓練。

陸、結語

本文作者在構思本篇論文時，曾與臺北大學社會系張恆豪教授、社工系王品教授就此議題討論交換意見，兩位學者的提問是，缺少無障礙設施，身障者就寸步難行，難道這不是一種歧視嗎？法律既有明文，為何不能透過訴訟獲得救濟？面對這樣的挑戰與質疑，在公法學領域廣為接受的保護規範說，顯得左支右絀難以招架。或許從權力分立的角度我們可以說，落實無障礙環境需要行政與立法部門積極作為，司法訴訟途徑並非最佳手段。但若設身處境思考，身障者面對行政機關長年怠惰未積極推動無障礙環境，每遇陳情就只給制式回覆，除非身障者因此遭遇意外或遭受污辱，透過民意代表召開記者會，才稍稍「動」起來著手規劃設施之改善，或者行政機關主張為保障在校園或公園中活動民眾的安全，受限於人力不足必須設置路障才能阻絕機車進入，至於身障者只是少數，礙難為其作特殊安排，難道這些行政作為或不作為均無適法性的疑

義？均不受司法權審查？

從我國、德國與歐洲人權法院審判實務結果來看，答案的確令人感到沮喪。不過隨著近年一波波國際人權公約內國法化的立法行動，身障權利公約不僅成為我國內國法之一部分，身障權利公約施行法更直接明文身障者權利無論是受到侵害，或是無法實現或難以實現時，均得提起法律救濟。身障權利公約施行法之訂定，無疑是國內身障人權法制發展的一大里程碑，在權利救濟途徑上一步跨出「保護規範說」的學理發展以及訴訟實務的侷限性，惟立法過程中缺乏司法人員的參與及討論，未來法官如何解釋適用施行法該項條文，有待觀察。除了開啟身障者個人救濟途徑外，在立法政策上，另行賦予公益團體訴訟權能，補充身障者個人訴訟權能不足，仍不失為全面監督政府落實無障礙環境的方法之一。開啟權利救濟途徑之後，下一階段的挑戰在於身障者權利與公共利益及第三人權利之間如何衡量的實體論證問題，我國的司法人員向來對於弱勢者所面臨的人權困境理解有限，在利益權衡上經常過度重視抽象的公共利益，而未能「看見」身障者所處的障礙環境，而這正是憲法增修條文第10條第7項身心障礙者權益條款以及身障權利公約內國法化的意義所在。憲法及國際人權法規範一再提示司法裁判者，身障者處於結構性弱勢地位，法官必須看見他們、認識他們的處境，站在這個出發點進行利益衡量。或許必須透過一次又一次的訴訟行動，才能促使法院正視憲法身障權益條款的規範意義，以及立法院透過身障權利公約內國法化，承認國家負有確保身障者享有平等參與社會權利的規範意義，依此檢視行政行為之適法性，並作為解釋無障礙環境相關法律及憲法增修條文之依據。

附錄：大眾運輸工具無障礙設施設置辦法部分條文

- 第4條 各級交通主管機關應依本法第十一條第一項之交通需求評估與服務調查研究結果，邀集相關身心障礙團體代表、當地大眾運輸業者及該管社政主管機關共同研商，於大眾運輸業者所服務之路線、航線或區域內，規劃適當路線、航線、班次、客車（機、船）廂（艙），提供無障礙運輸服務，並商訂實施時間。
- 第5條 大眾運輸工具設置無障礙標誌規定如下：
- 一、大眾運輸工具內，設有輪椅停靠位置或可供身心障礙者使用之衛生設備旁明顯處，應設置無障礙標誌。
 - 二、依前條規定提供無障礙運輸服務之大眾運輸工具，應於該運輸工具上明顯處，設置易於識別之無障礙標誌（如附件）。
 - 三、大眾運輸工具上設置之博愛座，應於明顯處標示博愛座字樣。
- 第6條 大眾運輸業者應將其所提供之無障礙運輸服務時間標示於時刻表、各場站告示牌及其他相關資訊、手冊上。
- 大眾運輸業者應設置服務（客服）中心，以提供身心障礙者之相關服務並將服務（客服）中心之聯絡資訊標示於時刻表、各場站告示牌、大眾運輸工具之輪椅停靠區及其他相關資訊上。
- 大眾運輸業者，對於主動表達有協助需求之身心障礙者，應提供人力協助服務，並依個別需求提供上下運輸工具之引導或協助服務、緊急求救器或服務鈴簡易使用指導。

第7條 公路及市區汽車客運客車應依下列規定設置輔助乘客上下客車之無障礙設施：

- 一、運行資訊標示設施：路線、起迄地點等資訊應以易於識別之文字、圖案、標誌及色彩標示於車輛外部適當位置。
- 二、入站播報設施：應於車輛適當位置設置車外廣播設備，以易於辨識的聲音或語音提供路線、起迄地點等運行資訊。
- 三、引導設備：於車輛適當位置設置車外廣播、燈號及字幕顯示等設備，以易於辨識的聲音或語音、燈號及文字提供車門位置及開閉資訊。
- 四、上下階梯：設置供乘客上下車輛之階梯，除踏步高外，階梯高度不得超過三十公分。超過三十公分應以斜坡板輔助並派專人服務。階梯踏面不得突出，應為粗面或經其他防滑材料處理；其與踏面邊緣應有明顯色差，可供辨識，並應設置扶手。在車門打開時，應有適當的照明。
- 五、昇降設備及出入口：供輪椅上下之車門，淨寬度不得小於八十公分；其輪椅無法單獨通過者，應設置可供輪椅上下之昇降設備、斜坡板並派專人服務。在車門打開時，應有適當的照明。

參考文獻

1. 中文部分

- Wolfgang Kahl著，林明鏘譯（2011），德國與歐盟行政法上主觀公法上權利之現況、演變及其展望，臺大法學論叢，40卷2期，頁877-906。[Kahl, Wolfgang (2009), Das subjektive öffentliche Recht im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht – Stand, Entwicklung, Perspektiven, http://www.law.ntu.edu.tw/ntlawjournal/mini_journal/English_abstract/40/40_2E/1-35%20%E6%9E%97%E6%98%8E%E9%8F%98_%E8%AD%AF%E5%8E%9F%E6%96%87.pdf.]
- 王國羽（2008），聯合國身心障礙者人權公約對我國的啟示，社區發展季刊，123期，頁106-116。
- 王國羽、呂朝賢（2004），世界衛生組織身心障礙人口定義概念之演進：兼論我國身心障礙人口定義系統問題與未來修正方向，社會政策與社會工作學刊，8卷2期，頁193-235。
- 吳庚（2012），行政法之理論與實用，12版，臺北：三民。
- 李明政等（2013），弱勢者教我們的事：社會工作之權利導向，臺北：松慧文化。
- 李建良（2010），行政訴訟實務十年掠影（二〇〇〇至二〇一〇年），月旦法學雜誌，182期，頁19-62。
- （2011），保護規範理論之思維與應用，收於：黃丞儀編，2010行政管制與行政爭訟，頁249-320，臺北：中央研究院法律學研究所。
- 李惠宗（2006），公物法，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁339-365，臺北：元照。
- 李震山（2007），行政法導論，7版，臺北：三民。

- 周伯峰（2014），「歧視禁止」作為私法自治的限制？——簡評德國《一般平等對待法》中的民事法上歧視禁止規定及其爭議，月旦法學雜誌，224期，頁127-150。
- 林明昕（2002），撤銷訴訟及撤銷訴訟之訴訟權能，法學講座，創刊號，頁75-92。
- 林騰鵠（2011），行政訴訟法，4版，臺北：三民。
- 法治斌（2006），行政法律關係與特別權力關係，收於：翁岳生編，行政法（上），3版，頁221-239，臺北：元照。
- 法務部（2012），公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約——一般性意見，臺北：法務部。
- 范揚（1955），行政法總論，2版，臺北：臺灣商務印書館。
- 孫迺翊（2011），再探視障按摩保留條款之合憲性——大法官釋字第649號解釋的法事實與法釋義，中研院法學期刊，9期，頁49-127。
- （2013），經濟社會文化權利國際公約與我國社會憲法之比較及其實踐——以社會保障權為例，收於：蘇宏達、陳淳文編，中華民國實施聯合國兩權利公約的意義：接軌國際，深化民主，頁153-196，臺北：財團法人臺灣民主基金會。
- 盛子龍（2001），撤銷訴訟之訴訟權能，中原財經法學，7期，頁1-46。
- 莊國榮（2013），行政法，臺北：元照。
- 陳柏霖（2011），論行政訴訟中「公法上權利」——從德國法與歐盟法影響下觀察，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 陳明里（2011），大道之行也，人輪平等——從下肢行動不便者的行路權、大眾交通運輸服務談起，法律扶助會訊，33期，頁22-26。
- 陳敏（2011），行政法總論，7版，臺北：自版。
- 陳清秀（2013），行政訴訟法，6版，臺北：元照。
- 陳新民（2005），行政法學總論，8版，臺北：元照。

黃俊杰（2011），行政法，3版，臺北：三民。

黃源協（2003），身心障礙福利的發展趨勢與內涵——國際觀點的分析，社區發展季刊，104期，頁342-359。

廖福特（2000），歐洲人權法院——歷史、組織、職權及程序，思與言，38卷4期，頁67-116。

——（2007），因為成功而改變，但是改革未完成——歐洲人權法院改革方案之分析，月旦法學雜誌，148期，頁57-77。

——（2008），從「醫療」、「福利」到「權利」——身心障礙者權利保障之新發展，中研院法學期刊，2期，頁167-210。

——（2011），國家積極義務與私人生活保障——歐洲人權法院2010年相關判決之檢視，台灣法學雜誌，180期，頁45-67。

劉如慧（2009），歐洲法對德國行政法的影響——以個人權利保護之訴訟權能為例，成大法學，17期，頁1-44。

——（2010），我國環境影響評估法判決回顧，興大法學，7期，頁275-308。

2. 外文部分

Arnardóttir, Oddný Mjöll. 2009. A Future of Multidimensional Disadvantage Equality?. Pp. 41-66 in *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives*, edited by Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn. Leiden: Brill.

Bickenbach, Jerome E. 2001. Disability Human Rights, Law, and Policy. Pp. 565-584 in *Handbook of Disabled Studies*, edited by Gary L. Albrecht, Katherine D. Seelman, and Michael Bury. Thousand Oaks, CA: Sage publications, Inc.

Degener, Theresia. 2003. Disability as a Subject of International Human Rights Law and Comparative Discrimination Law. Pp.151-184 in *The Human Rights of Person with Intellectual Disabilities*, edited

- by Stanley S. Herr, Lawrence O. Goston, and Harold Hongju Koh.
New York, NY: Oxford University Press.
- Drewes, Alexander (2009), Bindertenpolitik in Deutschland aus der Sicht hinderter Menschen, in: Maydell/Pitschas/Pörtner/Scuhlte (Hrsg.), Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien, Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 151-188.
- Gooding, Caroline, and Catherine Casserley. 2005. Open for All? Disability Discrimination Laws in Europe Relating to Goods and Services. Pp. 135-162 in *Disability Rights in Europe: From Theory to Practice*, edited by Anne Lawson and Caroline Gooding. Oxford: Hart Publishing.
- Koch, Ida Elisabeth. 2009. From Invisibility to Indivisibility: The International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Pp. 67-77 in *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives*, edited by Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn. Leiden: Brill.
- Majerski-Pahlen, Monika (2010), in: Neumann/Pahlen/Majerski-Pahlen (Hrsg.), SGB IX Kommentar, 12. Aufl., München: C. H. Beck, BGG § 4, § 8, §§ 12-13.
- Mowbray, Alastair. 2012. *Cases and Materials on the European Convention on Human Rights*. 3d ed. New York, NY: Oxford University Press.
- Osterloch, Lerke (2003), in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, 3. Aufl., München: C. H. Beck, § 3.
- Petri, Bernd/Stähler, Thomas (2008), Menschenrechte und Behinderung, ZESAR, S. 167-171.
- Quinn, Gerard, and Theresia Degener. 2002. *Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability*. New York,

NY: Oxford University Press.

Stein, Michael Ashley, and Janet E. Lord. 2009. Future Prospects for the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Pp. 17-40 in *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives*, edited by Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn. Leiden: Brill.

Straßmair, Stefan (2002), Der besondere Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, Berlin: Duncker & Humblot GmbH.

Trenk-Hinterberger, Peter (2009), Teilhaberechte behinderter Menschen in den Mitgliedsstaaten der EU, in: Maydell/Pitschas/Pörtner/Scuhlte (Hrsg.), Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien, Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 277-304.

Welti, Felix (2005), Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechtsstaat, Tübingen: Mohr Siebeck.

——— (2006), Das Recht auf Teilhabe hinderter Menschen in seinem verfassungs- und europarechtlichen Rahmen und im Spannungsfeld der neueren Sozialgesetzgebung, RsDE, S. 1-28.

——— (2012), Rechtliche Voraussetzungen von Barrierefreiheit, NVwZ, S. 725-730.

The Right to Accessibility for People with Disabilities:

A Legal Analysis of Enforcing the Governmental Obligation to Construct a Barrier-Free Environment through Litigation

*Nai-Yi Sun**

Abstract

According to Art. 10, Section 7 of the Additional Articles of the Constitution of the Republic of China and the Physically and Mentally Disabled Citizens Protection Act, the state shall construct a barrier-free environment to facilitate the full and equal enjoyment of all human rights by people with disabilities. However, this has only been partially implemented. Some people with disabilities have filed lawsuits against the government to eliminate obstacles around public facilities, or to provide for non-step buses. These lawsuits were defeated because of a lack of subjective public legal rights, which are required by both the theory of protective norms and the theory regarding the legal status of these using public facilities. In view of these recent cases, this article examines the regulations, theories and precedents in Taiwan from a comparative perspective with German legislation, in particular, the Act of Equal Treatment for People with Disabilities (*Behindertengleichstellungsgesetz*). Subsequently, the article discusses cases from the European Court of Human Rights (ECHR), and argues that universal human rights conventions (such as the ICCPR or ICESCR) often fail to acknowledge the systematic disadvantages of people with disabilities that result from obstacles in the environment. Finally, this article assesses the use of Article 8 of the Enforcement Act of the UN

* Professor of Law, College of Law, National Chengchi University.

Convention on the Rights of People with Disabilities, which entitles people with disabilities to file lawsuits not only due to a specific violation, but also because of the disregard of their rights protected by the Convention and other laws.

KEYWORDS: people with disabilities, barrier-free, legal claim of public law, theory of protective norms, legal status of users of public facilities, UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), public interest litigation, *Behindertengleichstellungsgesetz* (BGG).